

13/11/2023

SEGUNDA TURMA

**RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.983 DISTRITO
FEDERAL**

RELATOR	: MIN. ANDRÉ MENDONÇA
REDATOR DO	: MIN. GILMAR MENDES
ACÓRDÃO	
RECTE.(S)	: JOAREZ GOMES DE SOUZA
ADV.(A/S)	: LENINE POVOAS DE ABREU
RECDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). SERVIDOR PUNIDO COM PENA DE DEMISSÃO. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.

1. A aplicação das penalidades previstas no art. 127 da Lei 8.112/1990 vincula-se ao cumprimento de prerequisites estritos previstos na legislação de regência, apurados mediante a apreciação das características particulares de cada caso concreto em sede de processo administrativo disciplinar. A caracterização de tais requisitos não se sujeita a juízos de conveniência ou oportunidade da Administração e, portanto, é sindicável pela via judicial.

2. No controle judicial dos atos administrativos de demissão de servidor público estável, *“a legalidade do ato administrativo compreende, não só a competência para a prática do ato e as suas formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato”*, sendo certo que *“a inconformidade do ato com os fatos que a lei declara pressupostos dêle constitui ilegalidade, do mesmo modo que o constitui a forma inadequada que o ato porventura apresente”* (LEAL, Victor Nunes. Atos administrativos - Exame da sua validade pelo poder judiciário. **Revista de Direito Administrativo**, v. 3, p. 69–98, 1946).

3. Caso em que a penalidade de demissão aplicada pela Administração se deu sem devida caracterização do elemento subjetivo

RMS 38983 / DF

referente ao intuito de abandonar o cargo ocupado (Lei 8.112/1990, art. 138). Na espécie, a aplicação da penalidade de demissão violou direito líquido e certo do impetrante, uma vez que, valendo-se de fundamentação inconsistente e contraditória, calcada em presunções não corroboradas pelo acervo fático-probatório dos autos do PAD, a União aplicou-lhe a penalidade de demissão deixando de considerar a data em que efetivamente se deu o término de sua cessão informal ao Senado.

4. Recurso ordinário provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada sob a presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, conhecer do recurso ordinário interposto e dar-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade da Portaria-AGU n. 1.603, de 3 de novembro de 2009 e dos atos administrativos porventura praticados a tendo por fundamento, tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros André Mendonça (Relator) e Edson Fachin.

Brasília, Sessão Virtual de 10 a 20 de novembro de 2023.

Ministro GILMAR MENDES

Redator

Documento assinado digitalmente

03/07/2023

SEGUNDA TURMA

**RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.983 DISTRITO
FEDERAL**

RELATOR	: MIN. ANDRÉ MENDONÇA
REDATOR DO	: MIN. GILMAR MENDES
ACÓRDÃO	
RECTE.(S)	: JOAREZ GOMES DE SOUZA
ADV.(A/S)	: LENINE POVOAS DE ABREU
RECDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Joarez Gomes de Souza em face de acórdão da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 14.756/DF, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABANDONO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANIMUS ABANDONANDI. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Considerando o caráter manifestamente infringente da pretensão e o princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno, garantindo-se a ampla defesa com vista dos autos à defesa para

RMS 38983 / DF

complementação das razões, como no caso.

II - Nos termos dos arts. 138, 142, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990, 'considerando o trigésimo primeiro dia de abandono (27/08/2006) até a instauração do presente processo (14/11/2007) se passaram menos de 02 (dois) anos, [de modo que] não há o que se falar da extinção da pretensão punitiva do Estado'.

III - Segundo art. 93 da Lei n. 8.112/1990, 'O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; II - em casos previstos em leis específicas'. Assim, não há previsão legal de cessão tácita ou informal como forma de afastamento do servidor público para o exercício em outro órgão. De acordo com a norma, a cessão do servidor público somente pode ocorrer para o exercício de função ou cargo de confiança.

IV - No caso, a alegada 'cessão informal' não encontra respaldo legal e não legitima o abandono do serviço público do ora agravante durante o período de 27/7/2006 à 5/2/2007, porquanto, encerrado o período de prestação de serviços no Senado Federal, não se apresentou ao seu órgão de origem, como deveria ter feito, em atenção às determinações da Lei n. 8.112/1990.

V - "A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas, ressalvada a avaliação do grau de proporcionalidade da pena aplicada" (MS n. 13.771/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/06/2015).

VI - O mandado de segurança é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data* contra ilegalidade ou abuso de poder e, por isso mesmo, não possui campo para

RMS 38983 / DF

cotejo de matéria fático-probatória, demandando, ainda, para conhecimento, a comprovação de plano do direito alegado.

VII - No caso, não houve a efetiva demonstração de direito líquido e certo a ser tutelado na via do mandado de segurança. Observa-se que o ato de demissão foi precedido do processo administrativo disciplinar, a fim de que fosse verificada toda a situação funcional do agravante. O só fato de as conclusões do mérito do PAD terem sido desfavoráveis aos interesses do impetrante não é pressuposto de que haja direito líquido e certo a ser reparado via eleita.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”

2. Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança contra iminente ato de demissão a ser praticado pelo Advogado-Geral da União, a partir das conclusões obtidas no Processo Administrativo Disciplinar nº 00406.001471/2007-57, instaurado para apurar suposto abandono de emprego. Na inicial do *writ*, alegou, em síntese, a prescrição, a ilegalidade na adoção do rito ordinário para apuração da falta e a ausência de *animus abandonandi*. Em sequência, após a propositura da demanda, o impetrante informou que a demissão foi, efetivamente, levada a efeito pela Portaria nº 1.603, de 3 de novembro de 2009.

3. Em seguida, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, concedeu liminar no mandado de segurança, ao entendimento de que, com relação ao período de 27/07/2006 a 05/02/2007, a Administração Pública reconheceu que o impetrante esteve cedido informalmente para o Senado Federal, fato que eliminaria o *animus abandonandi*. Posteriormente, contudo, com o feito sob a relatoria do e. Ministro João Otávio Noronha, a ordem foi denegada, tornando sem efeito a liminar previamente concedida.

RMS 38983 / DF

4. Opostos embargos de declaração pelo impetrante, foram eles recebidos como agravo interno, ao qual, porém, foi negado provimento. Em novos embargos declaratórios, foi acolhida a pretensão do impetrante para anular o julgamento anterior e *“determinar a intimação do embargante para complementar, no prazo de 5 dias, suas razões recursais a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do novo CPC”*, o que foi efetivamente realizado.

5. Na sequência, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça recebeu os embargos de declaração do recorrente como agravo interno, porém negou-lhe provimento, dando origem ao aresto aqui impugnado.

6. No presente recurso ordinário, o recorrente sustenta que *“o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência clara no sentido de que para se configurar abandono de emprego (Lei nº 8.112/90, Art. 127, III) é primordial: (i) o animus do servidor; (ii) prejuízo para a Administração, e (iii) dano ao Erário”*, requisitos que, no seu entendimento, não teriam sido preenchidos.

7. A respeito do apontado *animus abandonandi* sustenta que *“nunca houve vontade deliberada de abandonar o emprego”* e que *“para além de muitos anos no serviço público sem qualquer histórico desabonador, seja na AGU, no Estado de Mato Grosso, no Senado, entre outros, o recorrente sempre solicitou à AGU as cessões, sendo que muitas sequer eram respondidas”*. Afirma que *“embora estivesse com a remuneração suspensa desde 01.06.2005, o servidor solicitou expressamente o seu retorno para a AGU em 05.02.2007, demonstrando a falta de intenção de abandonar a função primitiva ou de causar prejuízo ao Erário e à Administração”*.

8. Aduz que, no período de suposto abandono *“continuou exercendo atividades no Senado Federal junto ao Gabinete do Senador Antero Paes de Barros, porém, sem nomeação formal”*, o que demonstraria que *“os tais 193 dias de abandono ao serviço público citados pela AGU são irreais”*. Aponta, ainda, que *“o vínculo com o Parlamento só se encerrou em julho de 2008,*

RMS 38983 / DF

quando o então Primeiro Secretário, Senador Efraim Morais, expediu ofício devolvendo o servidor à AGU”.

9. Sobre o citado prejuízo ao erário, aponta que *“a remuneração do servidor foi suspensa pela AGU em 01.06.2005”* e que *“no período do suposto abandono não houve ônus financeiro para a AGU (01.06.2006 à 05.02.2007)”*, pelo que *“não ocorreu prejuízo aos cofres públicos”*.

10. Defende que não *“houve absolutamente nenhuma lesão à Administração Pública por ocasião de o recorrente estar desempenhando suas atividades em outro local (e sem ônus financeiro para a origem), sobretudo por desinteresse da AGU em dar finalidade ao servidor, a qual tinha conhecimento de que o mesmo estava atuando no Senado Federal, consoante se constata no seu registro funcional”*.

11. Sustenta que é impossível a cassação de sua aposentadoria, com base na seguinte argumentação:

“41. Por força da decisão de 13.11.2009 do Min. Jorge Mussi que deferiu a liminar no Mandado de Segurança, o RECORRENTE exerceu normalmente suas funções junto à AGU, inclusive sendo condecorado (2015). Em 21.12.2020 se aposentou (Portaria SGCS/AGU nº 146, DOU de 23.12.2020 – e-STJ fl. 611) e, posteriormente, ainda assim foi novamente homenageado (2022).

42. Porém, após a relatoria do *mandamus* ser alterada para o Min. João Otávio de Noronha, a medida de urgência foi revogada e a ordem denegada em março de 2021, cujo efeito prático foi o cancelamento da aposentadoria, já concedida há três meses. Insta consignar que a aposentadoria foi obtida com base no preenchimento dos requisitos legais com praticamente quatro décadas de trabalho.

(...)

45. Não há que se cogitar, ainda, a possibilidade de aplicação da pena de cassação da aposentadoria, visto que o

RMS 38983 / DF

implemento das condições para se aposentar [tempo de serviço + tempo de contribuição] ocorreu antes da aplicação da pena de demissão.”

12. Pondera que *“ainda que eventualmente seja constatado o abandono de emprego, a pena de demissão é absolutamente desproporcional e desarrazoada e estaria em total dissonância das circunstâncias do caso concreto, sobretudo por ofender a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica”*. Afirma que *“por envolver servidor de 67 anos, que já estava com aposentadoria deferida, sua única fonte de renda, é clarividente que o interesse público caminha para estabilizar a situação ao invés de anular o ato (proporcionalidade e razoabilidade), sobretudo em deferência ao princípio da dignidade da pessoa humana”*.

13. A União apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 138).

14. A Procuradoria-Geral da República se manifestou (e-doc. 154) pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA

Relator

03/07/2023

SEGUNDA TURMA

**RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.983 DISTRITO
FEDERAL**

VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):

1. O caso é de não provimento do recurso.

2. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Joarez Gomes de Souza contra ato coator do Advogado-Geral da União, que o demitiu do cargo de assistente jurídico, por ter sido apurada, em processo administrativo disciplinar, a prática de abandono de cargo no período de 27/07/2006 a 05/02/2007, infração prevista no art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990.

3. A leitura do extenso processo administrativo disciplinar permite inferir que o recorrente possui histórico funcional bastante dinâmico, contando, ao longo dos anos, com inúmeras alterações de lotação, com exercício de suas funções, reiteradamente, fora de seu órgão de origem.

4. Para facilitar a compreensão dos fatos apurados no PAD, que redundaram na aplicação de pena em desfavor do servidor, ora recorrente, circunscrevo a análise ora empreendida ao período de maior relevância para o deslinde da questão, qual seja, o que começa a partir de sua redistribuição para a Advocacia-Geral da União, em 2001. Para esclarecer o caso, transcrevo trecho do relatório final da Comissão Disciplinar de Inquérito, que ilustra a situação funcional do recorrente (e-doc. 6 p. 21-26).

“a) Quanto ao histórico funcional do acusado:

(...)

- 06.set.2001 - o servidor é redistribuído do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Advocacia-Geral da

RMS 38983 / DF

União, nos termos do art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43/01, não havendo notícia de que tenha tido exercício em qualquer unidade da AGU;

- nov.2002 - início do exercício irregular do acusado no Senado Federal, cf. Ofício nº 004/2004 do Senador Antero Paes de Barros (fls. 02 do Anexo I do Apenso I, fls. 01 do Apenso IV do Anexo IV e fls. 51 do Anexo II do Apenso I);

-01.jan.2004 - a AGU finalmente assume a folha de pagamento do servidor (fls. 12, dos autos principais do Apenso I; fls. 112 e 131 do Anexo I do Apenso I);

- 07.jan.2004 Ofício nº 004/2004 do Senador Antero Paes de Barros: primeira solicitação formal do Senado Federal à COGEP/MP para que o acusado fosse cedido (fls. 02 do Anexo I do Apenso I, fls. 01 do Apenso IV do Anexo IV e fls. 51 do Anexo II do Apenso I), sendo que o ofício acabou sendo remetido à AGU uma vez que agora o servidor já não mais pertencia aos quadros do Ministério do Planejamento;

- 16.mar.2004 - Informação nº 133-CGRH/DRHTI/SGAGU, em resposta ao Ofício do Senador Antero Paes, estabelecendo as condições para cessão ao Senado (art. 93, inciso I, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.112/90), isto é, somente para assumir cargo em comissão, às fls. 29 do Anexo IV do Apenso IV e às fls. 31 do Anexo I do Apenso I;

- 25.mar.2004 - despacho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, informando as mesmas condições, citando ainda o art. 3º, inciso II, do Decreto nº 4.050/01 e o Ofício-circular nº 32/2000 (fls. 64 do Anexo I do Apenso I);

- 03.mai.2004 - Senado Federal formaliza pela primeira vez a nomeação do acusado para o cargo em comissão de Assistente Parlamentar (símbolo AP-6), porém antes de a AGU autorizar a cessão; os atos são tornados sem efeito, diante da inexistência formal do ato de posse, e reeditados sucessivamente enquanto a autorização não é concedida, até que o Senador Antero Paes desiste da nomeação em jul.2006 (fls. 165- 200 dos autos principais do Apenso IV);

- 13.mai.2004 - Senado Federal informa à AGU que, para

RMS 38983 / DF

fins de cessão, o servidor seria nomeado para o cargo em comissão de Assistente Parlamentar (símbolo AP-6) no Gabinete do Senador Antero Paes (fls. 56-60 do Anexo I do Apenso I e fls. 54-59 do Anexo IV do Apenso IV), sendo que, no entanto, já havia sido nomeado à revelia do órgão de origem;

-09.nov.2004 - frequência do acusado no Senado Federal é confirmada até out.2004 (fls. 73 dos autos principais deste PAD), apesar de suas nomeações irregulares terem continuado até jul.2006;

- 22.fev.2005 - Nota DECOR nº 10/05-MMV (fls. 127-135 do Anexo I do Apenso I), firmando o entendimento da necessidade de regularizar a situação funcional antes da cessão, comprovando que a cessão nunca chegou a ser autorizada e, portanto, nunca ocorreu formalmente;

- jun.2005 - pagamento do servidor suspenso pela AGU por meio do Memorando nº 430/DRHTI/SGAGU, de 1º de junho de 2005 (fls. 93 do Apenso IV, anexo II);

27.jul.2006 - É publicado o Ato do Diretor-Geral do Senado nº 1509/2006; tornando sem efeito as nomeações do servidor no Senado Federal, diante da desistência do senador Antero Paes em virtude da não autorização da cessão pela AGU (fls. 166 e 180-181 do Apenso IV).

05.fev.2007 - requerimento de JOAREZ GOMES DE SOUZA solicitando o restabelecimento do pagamento e sua lotação na PU/MT, em Cuiabá, ou outro órgão de execução da AGU naquele Estado, vinte meses após ter seu pagamento suspenso (fls. 02-04 dos autos principais do Apenso I).

-19.jun.2007 - requerimento de JOAREZ GOMES DE SOUZA solicitando a sua exoneração do cargo de Assistente Jurídico, bem como a desistência do requerimento anterior (fls. 14 dos autos principais do Apenso IV);

- 05.mai.2008 - requerimento de JOAREZ GOMES DE SOUZA solicitando o cancelamento de seu pedido de exoneração (fls. 311-312 do presente PAD);

- 26.mar.2009 - retorno do acusado ao seu regular exercício, com designação de sua lotação no Gabinete do

RMS 38983 / DF

Advogado-Geral e exercício na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde (fls. 597 dos autos principais deste PAD), sendo este seu primeiro exercício regular desde que redistribuído para a AGU; a definição do local de exercício se deu por provocação do próprio servidor interessado mediante requerimento formulado em 19.fev.2009 e autuado sob nº 00400.001878/2009-04.”

5. A cronologia dos eventos, acima descrita, é relevante para a compreensão dos fatos apurados e das razões que levaram ao apenamento do recorrente.

6. De início, impende destacar que, a despeito de a apuração ter principiado com espectro temporal muito mais amplo, **ao fim do PAD, a partir das provas colhidas, a aplicação de pena deu-se somente em virtude de abandono de cargo identificado em período de menor extensão, correspondente a 27/07/2006 a 05/02/2007.**

7. Assim procedeu a autoridade julgadora, a partir das conclusões contidas em nota técnica da Corregedoria-Geral da Advocacia da União e no Relatório da Comissão Disciplinar, documentos em que se acolheu, em parte, o argumento defensivo no sentido de que havia certa desorganização administrativa que pode ter contribuído para a não configuração, de modo contundente, do abandono de cargo **em período anterior a julho de 2006.**

8. Assim, entendeu a autoridade julgadora que **somente estaria livre de dúvidas a configuração do abandono de cargo no período de 27/07/2006 a 05/02/2007,** período no qual ficou provada, acima de qualquer dúvida razoável, a presença do elemento objetivo, consistente na ausência do servidor por mais de trinta dias consecutivos, e do elemento subjetivo, configurado a partir da intencionalidade da ausência, ou seja, do denominado *animus abandonandi*.

RMS 38983 / DF

9. Adianto que, examinando, detidamente, a integralidade do processo administrativo disciplinar, **convenci-me da correção do posicionamento da Administração**. A meu sentir, a análise empreendida na instrução do feito deu-se com intensa verticalidade, a partir do exame de extensa documentação juntada aos autos do PAD e da prova produzida no apuratório, além de terem sido analisados, exaustivamente, os argumentos defensivos.

10. Noto, inclusive, o cuidado na apreciação das questões debatidas, que, a partir do exame minucioso da prova, **resultou em considerar o servidor faltoso apenas a partir de julho de 2006**, reconhecendo que, no período anterior, o comportamento da Administração pode ter contribuído para a falha, além de repousar incerteza nos autos sobre o quadro fático, a desautorizar juízo condenatório. Transcrevo trechos do relatório final da Comissão Disciplinar de Inquérito da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, que descrevem as razões que levaram à sugestão pela aplicação de pena de demissão ao recorrente:

“(...) b) Quanto ao abandono de cargo:

7°. Em 2001 o acusado já estava redistribuído para os quadros da AGU e, apesar da incerteza nos autos de ter estado ou não em exercício desde 1992 e de onde seria este exercício até seu ingresso na AGU, a partir de novembro de 2002 tal local de exercício já é certo e determinado, qual seja, o Senado Federal (vide histórico funcional retro). No entanto, também se trata de exercício irregular, em virtude de ‘cessão informal’, não amparada por qualquer ato da Advocacia-Geral da União.

8. Apesar dos indícios, não existe prova direta do *animus abandonandi* do servidor durante o período em que esteve informalmente cedido ao Senado Federal, até porque existiram atos de nomeação para cargo em comissão entre mai.2004 a jul.2006, embora tal nomeação jamais tenha sido autorizada pela AGU e a primeira nomeação tenha ocorrido à revelia do órgão de origem. Apesar de não haver comprovantes de frequência no Senado após out.2004, o servidor foi nomeado

RMS 38983 / DF

sem autorização da AGU até 26.jul.2006, quando o Senador Antero Paes finalmente desistiu da cessão. Seu pagamento foi suspenso na AGU em jun. 2005, mas somente reclamou de tal medida mais de um ano após a suspensão do salário, quando também parou de receber pelo Senado Federal. **Portanto, pelo menos até jun.2006 não se pode afirmar com segurança que o servidor não tinha a intenção de abandonar o cargo, apesar de injustificadamente faltoso, dada a irregularidade de sua situação.**

9º. A partir de 27.jul.2006, contudo, é incontroversa a sua intenção de abandonar o cargo, pois, além de já estar sem receber seu pagamento sem qualquer insurgência contra tal suspensão, sua nomeação para o cargo no Senado Federal foi tornada sem efeito definitivamente, e mesmo assim não retornou ao seu órgão de origem (AGU), nem sequer manifestou qualquer interesse neste sentido até fev.2009, já no curso do presente PAD, quando solicitou a definição de alguma unidade para ter exercício (processo nº 00400.001878/2009-04), ou pelo menos até 05.fev.2007, quando requereu o restabelecimento de seu pagamento (fls. 02-04 dos autos principais do Apenso I).

(...)

66. É incontroversa a autoria das irregularidades descritas na portaria inaugural e capituladas como infração disciplinar na indicição, no que tange ao possível abandono de cargo, visto que o servidor acusado no processo é aquele sobre o qual paira a imputação de ter abandonado sua função.

67. Com relação à materialidade da infração, porém, não se pode negar que se trata de fatos controvertidos, visto que o abandono de cargo, além de seu elemento objetivo, possui o elemento subjetivo da intencionalidade presente no tipo legal, e somente quando ambos os elementos estão presentes é que se pode falar em ilícito disciplinar.

(...)

Outrossim, há indícios de que **não houve a caracterização do tipo subjetivo do abandono no período entre nov.2002 e**

RMS 38983 / DF

jul.2006, enquanto esteve informalmente cedido ao Senado Federal, visto que a recusa expressa ao pedido de cessão nunca ocorreu de fato, e não havia na AGU definição alguma de sua situação funcional no que tange à lotação. Todavia, o elemento subjetivo da intencionalidade torna-se claro em momento posterior, quando, já com o pagamento suspenso pela AGU, o acusado deixa de servir no Senado e fica sem colocação no serviço público, tirando seu sustento exclusivamente da advocacia privada, sem qualquer providência no sentido de retornar às funções de Assistente Jurídico entre 27.jul.2006 e 05.fev.2007 (193 dias).

69. Assim, caracterizada também a materialidade da infração tanto em seu aspecto objetivo quanto no subjetivo, pelo menos durante parte do período apurado, houve elementos suficientes para a indicição da qual o acusado se defendeu.

(...)

c) No mérito: caracterização dos elementos típicos do abandono.

(...)

109. Apesar de frágeis as provas apresentadas pelo indiciado, não há, em contrapartida, outros elementos que demonstrem a intenção do servidor em abandonar o cargo até jul/2006, de modo que, diante de tal dúvida, não se vislumbra como sustentar a indicição inicialmente promovida no despacho de encerramento da instrução, ainda que demonstradas as faltas injustificadas ao serviço. Afinal, a mera demonstração da ausência ao serviço não basta para a caracterização do ilícito disciplinar capitulado no art. 138 da Lei nº 8.112/90.

110. No que tange ao período a partir de 27.jul.2006, no entanto, há nos autos elementos suficientes que permitem concluir pela intencionalidade do indiciado em cometer as faltas injustificadas nas quais incorreu.

111. A rigor, a própria permanência no Senado Federal sem a autorização da AGU já poderia ensejar a caracterização do dolo do servidor em cometer a transgressão disciplinar a ele

RMS 38983 / DF

imputada, se considerarmos que a insistência em permanecer em uma situação ilegal no Senado enquanto sua cessão não era autorizada possa caracterizar uma clara intenção de colocar seu cargo em segundo plano em relação a seus interesses pessoais ao ponto de abandonar sua função.

112. Todavia, considerando as circunstâncias específicas que permeiam sua situação funcional desde 1992, **tal argumento cede diante do fato de que a situação irregular do servidor pode mesmo ter tido origem na desorganização administrativa que o levou a não ter local de exercício definido durante anos nos órgãos onde esteve enquadrado após seu aproveitamento. Em síntese, ainda não há prova inequívoca da intenção de abandonar o cargo até a cessação de suas nomeações no Senado Federal, em 27.jul.2006 (fls. 166 e 180-181 do apenso IV).**

113. Tal intenção, porém, é inequívoca a partir de tal momento, pois nesta época o indiciado já estava com o pagamento suspenso pela AGU (fls. 93 do Apenso IV, anexo II) e, mesmo assim, não buscou retornar ao serviço, pelo menos até 05.fev.2007, quando requereu o restabelecimento de seu pagamento (fls. 02-04 dos autos principais do Apenso I). Não há como se alegar, durante tal período, que ainda buscava uma colocação no serviço público, pois já tinha conhecimento de que estava formalmente lotado na AGU e, mesmo após o término de sua 'cessão informal' ao Senado e a suspensão do pagamento, não buscou manter qualquer contato com seu órgão de origem a fim de retornar ao serviço. Ao contrário, permaneceu atuando na advocacia privada, já comprovada em outro PAD (Apenso IV) e pela qual foi condenado disciplinarmente. Caracterizado, assim, de forma inequívoca, um período de 193 dias de faltas intencionais sem justificativa, entre 27.jul.2006 e 05.fev.2007.

114. Registre-se, por oportuno, que a defesa escrita silenciou a respeito deste período em que o servidor continuou irregularmente ausente do serviço, muito embora tenha constado do despacho de indicição, no qual se imputou ao

RMS 38983 / DF

acusado, detalhadamente, o abandono desde 10.abr.1992 até a data do despacho. Posteriormente, verificou-se que o servidor chegou a retornar ao seu regular exercício em 26.mar.2009, após ter-se apresentado à AGU em 01.jul.2008 (defesa escrita, fls. 483 e seguintes). No entanto, **nada foi alegado como justificativa para a ausência no referido período de 193 dias, a não ser alegações genéricas e esparsas de que somente foi convocado para trabalhar por meio do Ato Regimental nº 8/2007 (fls. 602-603), e de que teria ajuizado mandado de segurança para que fosse designado o seu local de exercício.** Alegações que, a bem da verdade, não descaracterizam sua intenção de abandonar a função no período ora apontado, pois se **trata de providências que o indiciado somente procurou impulsionar após ter sido notificado da instauração do presente processo administrativo disciplinar contra sua pessoa.** Além disso, o referido ato regimental não trata da situação do indiciado, que se encontrava ilegalmente ausente de seu órgão de lotação, mas referia-se a todos os membros da AGU regularmente cedidos, mas que por força de nova regulamentação superveniente deixaram de atender aos requisitos necessários para estarem cedidos, devendo retornar às suas unidades de exercício sem possibilidade de renovação das cessões (conforme art. 1º do ato regimental).” (grifos nossos).

11. O relatório final da Comissão Disciplinar foi corroborado pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União que, por meio da Nota Técnica nº 141-2009-CGAU/AGU (e-doc. 9), apreciou, exaustivamente, a questão e os argumentos defensivos, mantendo a orientação pela demissão do servidor. A despeito da sua extensão, peço vênica para transcrever trechos em que analisadas as provas e as teses defensivas, por entender que situam bem a questão:

“(…) 63. Por oportuno, alguns esclarecimentos adicionais sobre o período em que o servidor esteve cedido de forma NÃO AUTORIZADA ao Senado Federal devem ser feitos, pois, conforme dito no item 42 supra, esteve prestando serviço de

RMS 38983 / DF

forma irregular como assessor do Senador Antero P. de Barros entre NOVEMBRO/2002 A 26/07/2006.

64. Com efeito, por meio de ofício datado de 07/01/2004 (fls. 02 e seguintes do Anexo I do Apenso I), dirigido ao Coordenador de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, o aludido Senador comunica que o Sr. JOAREZ GOMES DE SOUZA esteve prestando serviço na sua assessoria parlamentar e com frequência devidamente atestada desde novembro de 2002 até 07/01/2004. Em seguida, o MPOG remeteu tal expediente à Advocacia-Geral da União informando que a referida cessão NÃO HAVIA SIDO FORMALIZADA.

65. Essa parece ser mais uma possível incongruência da certidão citada no item 58 desta Nota, que atesta a frequência normal do servidor até o final de 2003, inobstante o fato de que desde o mês de novembro de 2002 esteve INFORMALMENTE cedido ao Senado Federal.

66. Ao que parece, a formalização do pedido de cessão à AGU somente ocorreu em março de 2004, conforme Ofício nº 062/2004, da Presidência do Senado Federal (fl. 34 do Anexo I do Apenso I).

67. No entanto, a partir do recebimento do pleito de cessão, foi constatada a imprecisão nas informações relativas à situação funcional do servidor, fazendo com que processo de cessão tramitasse na Administração Pública por tempo razoável ao deslinde da questão.

68. Ao final, diante das fundadas dúvidas quanto à frequência do servidor ao longo dos anos, a análise de mérito do pedido de cessão restou prejudicada, pois havia a necessidade de se estabelecer, com precisão, o período em que efetivamente esteve no exercício das atribuições do seu cargo.

69. A par disso, mesmo não tendo sido decidido o pedido de cessão pela Administração, o Senado Federal, desde 03/05/04, promoveu uma série de nomeações que foram sendo tornadas sem efeito e reeditadas sucessivamente enquanto se aguardava o desfecho da cessão. **A última nomeação foi tornada sem efeito pelo Ato do Diretor-Geral do Senado nº**

RMS 38983 / DF

1.509, publicado no dia 27/07/06, conforme documento de fls. 180/181 do Apenso nº 4, *in verbis*:

ATO DO DIRETOR-GERAL Nº 1509, DE 2006

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Resolução do Senado Federal nº 07, de 2002, e tendo em vista o que consta dos processos nºs 001174/04-8, **RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Diretor-Geral nº 281, publicado no Boletim Administrativo de Pessoal do Senado Federal nº 3421, de 13/02/2006, que nomeou JOAREZ GOMES DE SOUZA para exercer o cargo, em comissão, de Assistente Parlamentar, AP-8, do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros, em virtude de não ter tomado posse no prazo previsto pelo § 1º do art. 13 de Lei nº 8.112/90, de 1990.**

Senado Federal, 26 de julho de 2006. Agaciel da Silva Maia, Diretor Geral.

70. Essa informação, ao que consta destes autos, foi prestada pelo Diretor-Geral do Senado Federal em expediente datado de 20 de agosto de 2007, dirigido diretamente ao Presidente da Comissão de Inquérito instituída nos autos do **Processo Administrativo Disciplinar nº 00406.000362/2007-12 (cuja cópia constitui o Apenso 4 deste PAD), que apurou a prática de advocacia fora das atribuições institucionais pelo mesmo acusado, Sr. JOAREZ GOMES DE SOUZA, que foi punido com a pena de suspensão por 90 (noventa) dias.**

71. Feitos os apontamentos acima, especificamente em relação ao período compreendido entre janeiro/2004 até 26/07/2006, é razoável admitir que o fato de não ter sido apreciado o mérito da cessão, por si só, já impede o abono dos dias de remuneração em que o servidor não esteve à disposição da Advocacia-Geral da União, de modo que, salvo melhor juízo, a Administração deve ser ressarcida pela remuneração paga indevidamente no período considerado, ao menos até o mês de junho de 2005, data em que foi suspenso o pagamento dos respectivos vencimentos, conforme consta do Memorando nº

RMS 38983 / DF

430/DRHTI/SGAU, de 1º de junho de 2005,¹² a partir da constatação de irregularidades na sua situação funcional.

72. Todavia, não obstante as ausências injustificadas ao serviço, como posto acima, há de se concluir que não há provas inequívocas quanto a um dos requisitos da infração de abandono de cargo, qual seja, a intencionalidade na conduta do acusado.

73. Com efeito, apesar da irregularidade de todo o procedimento, o pedido formal de cessão já estava sob o crivo da Administração da Advocacia-Geral da União desde o início de 2004, oportunidade em que foi constatada a existência de várias inconsistências na vida funcional do interessado, que estava pendente de regularização.

74. Repetimos a transcrição da conclusão da comissão a esse respeito feita no item 52 supra:

(...). 109. Apesar de frágeis as provas apresentadas pelo indiciado, não há, em contrapartida, outros elementos que demonstrem a intenção do servidor em abandonar o cargo até jul/2006, de modo que, diante de tal dúvida, não se vislumbra como sustentar a indicição inicialmente promovida no despacho de encerramento da instrução, ainda que demonstradas as faltas injustificadas ao serviço. Afinal, a mera demonstração da ausência ao serviço não basta para a caracterização do ilícito disciplinar capitulado no art. 138 da Lei nº 8.112/90.

75. Contribuiu para a fragilizar a ocorrência do dolo nas ausências até esse dia (26/07/2006) o fato de que havia registros na Administração de que o interessado estaria de alguma forma à disposição do Senado Federal, mesmo que em situação flagrantemente irregular.

76. É o que se deduz da leitura da já mencionada NOTA DECOR/CGU Nº 054/07, in verbis:

(...) Destarte, não consta no assentamento funcional do servidor (colacionados aos autos apensados/anexados) quaisquer documentos autorizando sua cessão. Ressalte-se, por fim, que, em que pese não haver nenhum

RMS 38983 / DF

documento nos autos formalizando a cessão para o Gabinete do Senador Antero Paes, o servidor Joarez Gomes de Souza, conforme informação disponível o sítio da AGU, ocupa o cargo de Assistente Jurídico, lotado na Consultoria Geral da União com exercício no Senado Federal.

(...)

11. Em sendo assim, até o deslinde dos processos em apenso, quando será resolvido em definitivo a situação funcional do servidor Joarez Gomes de Souza, é de se considerar o interessado ocupante do cargo de Assistente Jurídico, lotado na Consultoria Geral da União com exercício no Senado Federal, conforme consultado no sítio da AGU.'

77. Consigne-se que a manifestação acima transcrita foi elaborada em 19/03/2007, quando, aparentemente, ainda não se tinha conhecimento de que a última nomeação do servidor havia sido tornada sem efeito em 26/07/06. Essa informação teria sido prestada pelo Senado somente em 20/08/07, por meio de expediente endereçado diretamente ao Presidente da comissão alusiva ao Processo nº 00406.000362/2007-12, conforme já assinalamos no item 70 supra.

78. Em suma, para fins de caracterização da infração do art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990, é possível concluir o seguinte:

78.1 em face dos fundamentos contidos nos itens 51 a 62 acima, não merece prosperar o período de abandono considerado na indicição que vai de 10 de abril de 1992 a até dezembro de 2003, pois tal lapso temporal encontra-se abrangido pelas certidões de tempo de serviço emitidas pela própria Administração (1988 a 2003), que presumem-se verdadeiras até prova em contrário, em que pese os vários indícios de irregularidades quanto aos dados ali contidos;

78.2 o tempo em que o servidor esteve prestando serviço ao Senador Antero Paes sem qualquer pedido de cessão formalizado (novembro/2002 a dezembro/2003), embora caracterizado pela ilegalidade, não pode ser computado como

RMS 38983 / DF

falta ao serviço, pois, da mesma forma, tal período também está abrangido pelas certidões expedidas pela Administração;

78.3 já pelas razões esposadas nos itens 64/77 desta Nota Técnica, deve ser acatado o entendimento da comissão de que não ficou bem claro o dolo nas faltas injustificadas relacionadas ao período em que o Senado Federal aguardou o trâmite do pedido FORMAL de cessão do servidor junto à AGU (07/01/2004 a 26/07/2006), pois, apesar do mérito do pedido não ter sido apreciado, havia ainda o interesse do Senado em colocá-lo à disposição daquela Casa de Leis.

79. De outra banda, concluiu a comissão pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos desde que foi publicado o ato tornando sem efeito a sua nomeação no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros, fato esse ocorrido em 27/07/2006.

(...)

90. Para a melhor compreensão da questão, recapitulamos o histórico dos fatos ocorridos.

90.1 conforme dito nos itens anteriores, desde o ano de 2004 o Senado tentava junto à Advocacia-Geral da União a cessão do Assistente Jurídico Joarez Gomes de Souza, como fito de nomeá-lo para o cargo de assessor Parlamentar daquela Casa Legislativa.

90.2 em face de inconsistências na vida funcional do referido servidor, o mérito do pedido não chegou a ser examinado pela Administração. Não obstante isso, sem qualquer autorização ou deferimento por parte do órgão cedente, o Senado promoveu a nomeação do servidor sucessivas vezes nos dois anos subsequentes (2004 a 2006), todas tornadas sem efeito na medida em que se esgotava o prazo para a posse estabelecido na Lei nº 8.112, de 1990.

90.3 assim sendo, o Senador Antero Paes de Barros desistiu definitivamente da cessão ainda em 2006.

90.4 em consequência, por meio do Ato nº 1509/2006, de 26/07/2006, publicado no dia 27/07/2006, do Diretor-Geral do Senado Federal, a última nomeação do servidor para exercer

RMS 38983 / DF

cargo comissionado naquela Casa de Leis foi tornada sem efeito.

90.5 somente em 05/02/2007, quase 08 (oito meses) após a publicação do ato que tornou sem efeito a sua última nomeação no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros e decorridos quase 2 (dois) anos desde a suspensão do seu pagamento, em junho/2005, vem o servidor requerer junto à Instituição o restabelecimento da remuneração do cargo de Assistente Jurídico, mesmo sabendo da ausência de qualquer prestação de serviço decorrente de suas funções jurídicas no âmbito da AGU. Por fim, no mesmo expediente, solicitou o interessado que sua lotação fosse fixada na cidade de Cuiabá/MT (fls. 2 a 4 do Apenso I, Principal).

91. Diante desses fatos devidamente comprovados nos autos e considerando o tempo decorrido entre os dias 27/06/2006 e 05/02/2007, concluiu a comissão que, neste período de 193 (cento e noventa e três) dias, ficou evidenciada a ausência intencional do indiciado.

92. Manifestamo-nos de acordo com esse entendimento, pois as evidências colhidas na instrução do feito demonstram claramente essa situação, senão vejamos.

93. Como bem demonstrado nos autos, a ‘prestação de serviço’ do servidor no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros cessou definitivamente em 27/07/2006, por desistência da sua nomeação para ocupar cargo naquela Casa de Leis.

94. Pois bem. Finalizada essa cessão informal e mesmo com o pagamento alusivo ao cargo de Assistente Jurídico suspenso desde julho/2005, ao invés de apresentar-se de imediato para exercer de fato suas atribuições junto à Advocacia-Geral da União, preferiu o acusado, no entanto, estabelecer-se na Cidade de Cuiabá onde confessadamente possuía escritório profissional para dedicar-se ao exercício de advocacia fora das atribuições institucionais, inclusive contra a União e suas Autarquias, o que constitui flagrante inobservância do impedimento estabelecido no art. 30, inciso I, do Estatuto da OAB.

RMS 38983 / DF

95. Se o servidor indiciado não quis deliberadamente abandonar o cargo, no mínimo assumiu o risco dessa conduta ao não retornar de imediato ao órgão de sua lotação tão logo deixou de 'prestar serviço' ao Senado Federal. Nem mesmo se apresentou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde tinha sua lotação antes de ser redistribuído à AGU.

96. Na verdade, **o desinteresse do servidor em não trabalhar na Instituição era evidente, tanto que apresentou pedido de EXONERAÇÃO do cargo após o término do mandato do Senador Antero Paes de Barros, embora tenha formalizado esse desejo de forma tardia, no dia 19/06/2007, quando já decorridos mais de 31 dias desde a sua saída do Senado.**

97. Eis o teor do requerimento de exoneração de fl. 14 do Apenso 4 deste PAD:

Cuiabá, 19 de junho de 2007.

Senhor Advogado-Geral da União,

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar minha desistência do pedido formulado em em 05/02/2007 através do requerimento NUP: 00400.000290/2007-63 e, via de consequência, solicitar EXONERAÇÃO do cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, matrícula SIAPE nº 0440153.

98. Ao ser interrogado nos autos do processo pelo qual foi punido pela prática de advocacia privada, autos esses que, por cópia, integram o citado Apenso 4 deste PAD (fls. 226/229), o Sr. **Joarez Gomes de Souza, além de confessar possuir escritório profissional em Cuiabá/MT há 06 (seis) anos, afirmou categoricamente não querer mais qualquer vínculo com a Administração Pública Federal, motivando, assim, o seu pedido de exoneração para estabelecer-se naquela Cidade, mesmo ciente de que sua lotação estava fixada em Brasília.** Confira-se:

'(...). Ao término do mandato do Senador, solicitou lotação em Cuiabá, a qual não foi atendida, tendo então

RMS 38983 / DF

solicitado exoneração do cargo.

(...)

Perguntado por quanto tempo esteve cedido para o Senado Federal, respondeu que desde 2002 até o final do mandato do Senador, no final de 2006.

(...)

Perguntado se possui escritório profissional na cidade de Cuiabá, respondeu que sim; Perguntado há quanto tempo está estabelecido em Cuiabá como advogado, respondeu que aproximadamente há 6 (seis) anos (...). Perguntado QUAL A RAZÃO DE SEU PEDIDO DE EXONERAÇÃO protocolado em 2007 e juntado aos autos em apenso a este PAD, RESPONDEU QUE NÃO DESEJA MAIS CONTINUAR NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL (...).

99. Outra evidência que demonstra o descaso em relação à Instituição reside no fato de que o acusado não se dignou a comunicar que a sua última nomeação como Assessor Parlamentar havia sido tornada sem efeito desde 27/07/2006, momento a partir do qual não foi apresentado qualquer indicativo no sentido de que o Senado ainda tinha algum interesse por sua cessão.

100. Ao contrário, a prova documental revela que o então Senador Antero Paes de Barros DESISTIU de nomear o servidor como seu assessor Parlamentar ainda em 2006. É o que consta do Ofício nº 097/07-DGER, de 20/08/07, do Diretor-Geral do Senado (fl. 165 do presente processo disciplinar, integrante do Apenso 4 deste PAD), o qual transcrevemos, *in verbis*:

Reporto-me ao Ofício nº 5/2007-CI/PAD/CGAU/AGU, referente à cessão ao Senado Federal do senhor JOAREZ GOMES DE SOUZA. Na oportunidade, informo que de acordo com esclarecimentos da Secretaria de Recursos Humanos desta Casa Legislativa (cópia anexada) os Atos de nomeação do servidor foram, sucessivamente, tornados sem efeito, à medida em que venciam o prazo de trinta dias previsto na

RMS 38983 / DF

Lei nº 8.112/90 para a posse, **ATÉ QUE O EX-SENADOR DESISTIU DA NOMEAÇÃO.**

101. Por parte do Senado Federal, conforme expressamente consignado na primeira parte do expediente acima transcrito, essa informação só foi prestada após formal solicitação do Presidente da Comissão designada nos autos do Processo nº 00406.000362/2007-12, que apurou a advocacia privada por parte do mesmo acusado, que foi punido com a pena de suspensão.

102. Por parte do acusado, **somente no dia 05 de fevereiro de 2007, veio o mesmo a comunicar que não se encontrava mais a serviço do Senado, isso passados quase oito meses da publicação do ato que tornou sem efeito a sua última nomeação como assessor Parlamentar e, ainda assim, com objetivos outros que não o alertar a Administração acerca da sua real situação.**

103. Portanto, TÃO LOGO findou a sua disponibilidade no Senado, em 27/07/09, deveria o servidor ao menos procurar o seu órgão de lotação na AGU para entrar em exercício no cargo de Assistente Jurídico do quadro suplementar da Instituição. Mas assim não procedeu, incidindo, via de consequência, na infração de abandono de cargo entre 27/06/06 a 05/02/07.

104. **Ainda que não tivesse havido a desistência da cessão em meados de 2006, a permanência do Assistente Jurídico Joarez Gomes de Souza no Senado Federal só poderia se justificar até o término do mandato do ex-Senador Antero Paes de Barros, QUE FINDOU EM 31/12/2006, momento a partir do qual o próprio servidor declarou ter se desligado em definitivo daquela Casa Legislativa para retornar à cidade de Cuiabá/MT, como se verá mais adiante.**

105. **Mesmo na hipótese acima aventada, ainda assim teriam transcorridos mais de 30 dias consecutivos de ausência ao serviço até o dia 05/02/2007, caracterizando o abandono de cargo.**

(...)

111. Preliminarmente, há de se destacar que o caso de

RMS 38983 / DF

abandono do indiciado não pode simplesmente ser comparado aos demais casos, dado o contexto peculiar em que está inserido. Essa constatação se dá por um fato documentalmente comprovado nos autos: **A VALIDADE DA CESSÃO DO SERVIDOR, EMBORA NÃO APRECIADO O PEDIDO FORMALIZADO A ESSE RESPEITO, JÁ HAVIA SE ENCERRADO DESDE 27/07/2006, QUANDO O SENADOR DESISTIU DE NOMEÁ-LO COMO SEU ASSESSOR.**

112. Logo, não se está discutindo a intencionalidade do abandono durante o tempo em que tramitou o pedido de cessão, que teve início em 2004, mas sim, no período iniciado com a data em que foi tornada sem efeito a última nomeação do servidor por ato do próprio Senado, em 27/07/06, ou seja, quando não se encontrava mais prestando serviços àquela Casa. Isso é o que demonstra a farta prova produzida pela comissão da qual a defesa não logrou êxito em refutar.

113. Tanto é que, entre janeiro/2004 até o dia imediatamente anterior à publicação do ato pela Direção-Geral do Senado, em 26/07/2006, a própria comissão reconheceu a deficiência de maiores elementos configuradores do dolo, não obstante a ausência de justificativa legal para as ausências ao serviço por parte do acusado, já que não poderia trabalhar em local para o qual não havia sido previamente autorizado pela Administração competente.

114. Feitas tais considerações, não há que se espelhar o caso do acusado pelo exemplo dado pelo acórdão do STJ.

115. Quanto à impossibilidade de se atribuir a data de 27/07/06 como sendo o termo inicial do abandono, sob o argumento de que a AGU não teria expedido a portaria de exercício tão logo publicado o ato tornando sem efeito a nomeação como Assessor Parlamentar, há de se esclarecer apenas que a Administração não poderia mesmo adotar tal providência, pois, na verdade, ainda não sabia da desistência da cessão e sequer foi informada a respeito.

116. O que pretendeu dizer o nobre causídico? Que a Administração Pública Federal deveria adivinhar o dia exato

RMS 38983 / DF

em que seria publicado um ato interna corporis daquela Casa Legislativa?

117. Ora, convenhamos que não se pode simplesmente atribuir à Administração essa suposta omissão quando até então somente o indiciado conhecia a sua situação particular. Mesmo assim, manteve-se silente até o dia em que se dirigiu ao Advogado-Geral da União para restabelecer o seu pagamento (05/02/07) e, no mesmo documento, dar de alguma forma a notícia que não estaria mais a serviço do Senado, isso depois de passados quase oito meses da publicação do multicitado ato que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de Assessor Parlamentar.

118. Até então, presumia-se o seu exercício naquela Casa Legislativa, ainda que irregular.

119. E mais. Mesmo que considerássemos a hipótese de que a cessão tivesse sido deferida pela Administração e seu término comunicado desde julho/2006, o que parece não ter ocorrido, qual deveria então ser a conduta esperada do acusado? Ficar sem trabalhar indefinidamente apenas pelo fato de que a Administração não teria editado uma portaria designando um novo local de exercício? Será que a ciência prévia por parte do interessado da existência de uma unidade de lotação não seria suficiente para que se apresentasse ao menos no órgão de recursos humanos da Instituição assim que deixasse de exercer suas funções no Senado? Essa é a tese que parece estar sendo sustentada pela defesa ao simplesmente dizer que o indiciado estaria impedido de trabalhar na AGU enquanto não fosse editado um ato específico de exercício. A moralidade e a probidade administrativa não sustentariam essa hipótese.

120. Diz ainda a defesa que somente com a publicação da Portaria nº 413, de 24/03/2009, publicada no DOU de 26/03/2009, o indiciado teve o seu exercício designado pela AGU, conforme consta da Declaração firmada pelo Chefe da Divisão da CGRH/AGU.

121. De fato, essa é a única portaria de exercício do

RMS 38983 / DF

indiciado.

122. Por outro lado, resta incontroverso que o exercício em Unidade da AGU não lhe foi dado antes justamente porque não se apresentou quando devia e **nem comunicou que o Senado havia desistido da sua cessão, fato esse ocorrido em 27/07/2006, mantendo a Administração em erro quanto ao seu real local de exercício.** Ao contrário, somente em 05/02/2007 procurou a Instituição para tentar reverter a suspensão dos seus vencimentos e para requerer a mudança da sua lotação de Brasília para a cidade de Cuiabá/MT. Ao não lograr êxito nesse intento, preferiu pedir exoneração por não ser de seu interesse continuar no serviço público.

123. Enfim, não obstante as falhas verificadas no controle da vida funcional do acusado, não pode a Administração ser taxada como omissa a respeito de fato cuja providência, no caso concreto, cabia tão-somente ao interessado.

124. Portanto, não é somente a ausência ao serviço que restou configurada, como reconhece a defesa, mas também o dolo da conduta de abandonar o cargo pelo indiciado, pelo que reputamos como improcedentes os argumentos sintetizados nos subitens 109.1 a 109.7 desta Nota.

125. Prossegue o Memorial aduzindo o seguinte:

125.1 que o servidor Joarez Gomes de Souza compareceu à AGU logo quando recebeu comunicação para apresentar-se, o que se deu em 19/07/2008, em razão da Carta nº 140-DIRES/CGRHTI/SGAU, de 16/05/2008, com o seguinte teor:

Prezado Senhor,

Informo a Vossa Senhoria que, de acordo com o art. 2º do Ato Regimental nº 8, de 14 de dezembro de 2007, publicado no Diário Oficial da União nº 241 - Seção 1, de 17 de dezembro de 2007, o seu retorno ao órgão de lotação deverá se dar até 1º de julho de 2008.

Tendo em vista que é lotado em Brasília/DF,

RMS 38983 / DF

informo, ainda, que a sua apresentação deverá ocorrer junto ao Gabinete do Advogado-Geral de União. Substituto, para que seja designado o novo órgão em que passará a ter exercício. consoante as Portarias nºs 550 e 551-AGU, ambas de 6 de junho de 2007.

125.2 a despeito de ter se apresentado, ainda assim não foi dado o exercício ao acusado, que continuou sem trabalhar, provando que não houve a intenção de abandonar, pois incumbe à Administração dar-lhe exercício;

125.3 em razão disso, o indiciado ingressou na Justiça Federal do Distrito Federal com Mandado de Segurança para que fosse garantido o seu direito de retornar ao serviço (Processo nº 2008.34.00.039642-1);

125.4 nas informações foi dito que não haveria óbice para que o servidor assumisse suas funções e entrasse em exercício. No entanto, a Coordenadora-Geral de Recursos Humanos da AGU disse ao advogado do acusado que o retorno do acusado estava sub-judice em razão do citado mandado de segurança, havendo dúvidas ainda quanto à possibilidade de retorno do servidor em razão da existência de processo administrativo disciplinar contra a sua pessoa em andamento;

125.5 foi requerido, então um posicionamento do Advogado-Geral da União a respeito dessa situação, culminando com a elaboração da Nota Técnica nº 292, aprovada pela Diretora do DAJI em Despacho datado de 18/03/2009. Somente a partir de então houve a designação do indiciado para trabalhar na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, por meio da citada Portaria nº 413, de 24/03/2009;'

126. Em primeiro lugar, repetimos o que já foi dito por várias vezes: o período considerado como de abandono vai de 27/07/2006 (quando teve sua nomeação no Senado Federal tornada sem efeito) até 05/02/2007 (quando solicitou ao

RMS 38983 / DF

Advogado-Geral da União a alteração da sua lotação de Brasília para a Cuiabá/MT, por não estar mais no Senado). A partir de então, nada está sendo imputado ao acusado, até porque, desde jun/2005 o acusado já estava com seu pagamento suspenso. É exatamente dentro desse período destacado que estão sendo analisados tanto a ausência ao serviço - já reconhecida pela defesa - como o dolo da conduta.

127. Nesse passo, o fato de eventualmente ter atendido à convocação para se apresentar em 19/07/2008 não afasta a materialidade nem a autoria do abandono no tempo considerado.

128. De qualquer modo, essa apresentação em julho de 2008 se deu em momento distinto e decorreu de ato administrativo que cumpria finalidade genérica da Administração em matéria de cessão de servidores dos quadros jurídicos da AGU (Ato Regimental AGU nº 08, de 14/12/2007), ou seja, sem levar em conta a situação peculiar do acusado, que já respondia pela infração de abandono desde o ano de 2007, cujas circunstâncias foram objeto de apuração específica somente no curso deste processo disciplinar.

129. No momento, cabe afastar a tese de que a apresentação do acusado ao trabalho seria obrigatória apenas na data limite estabelecida no corpo do referido Ato Regimental AGU nº 08/2007, pois a cessão regulada nesse ato normativo não contempla a situação de permanência ilegal do acusado no Senado Federal, o que será demonstrado mais adiante, em cotejo com o que foi dito na peça defensiva.

130. No mais, **se o acusado não entrou em exercício em 2007 foi porque se negou a trabalhar em Brasília, tanto que pediu exoneração do cargo assim que soube que não seria deferido o seu requerimento de alterar sua lotação para a cidade de Cuiabá/MT. A desistência do pedido de exoneração somente foi formalizada em 05/05/2008.**

131. **Esse interesse tardio de querer entrar em exercício, inclusive com a impetração de mandado de segurança, somente foi demonstrado quando já devidamente em curso**

RMS 38983 / DF

processo disciplinar destinado a apurar falta funcional capaz de infligir pena de demissão.

132. Por fim, os eventuais incidentes na tramitação do processo de reinclusão do acusado na folha não afastam a intencionalidade da ausência ao serviço apurada nestes autos, especialmente considerando a notória situação de irregularidade na anterior prestação de serviço no Senado Federal, fato esse que, como vimos, não se pode ser imputado apenas à Administração.

133. Sem fundamento, também, as alegações da defesa resumidas nos subitens 125.1 a 125.5.

134. A partir do capítulo III dos seus Memoriais, o acusado segue afirmando o seguinte:

134.1 o Dr. Joarez Gomes de Souza estava cedido ao Senado Federal desde novembro de 2002, ou seja, em momento anterior ao qual a AGU assumiu a sua folha de pagamento, pois passou aos quadros da Instituição em janeiro de 2004;

134.2 a referida cessão era informal, um autêntico caso de cessão tácita, já que nunca foi regularizada, apesar de insistentes pedidos daquela Casa de Leis;

134.3 mesmo após 27/07/2006, com a publicação do Ato do Diretor-Geral do Senado, o servidor continuou cedido informalmente prestando serviço com o consentimento informal da AGU;

134.4 com a intenção de regularizar a situação irregular do indiciado - e de outros advogados da Instituição, foi baixado o Ato Regimental nº 08/2007, dispondo sobre as cessões irregulares dos membros da AGU, visando o retorno dos mesmos aos quadros da Instituição;

134.5 exatamente por ter a AGU reconhecido que o indiciado se enquadrava na situação de cessão irregular disposta nesse Ato Regimental é que foi feita sua convocação por meio da Carta nº 140-DIRES/CGRHTI/SGAU, de 16/05/2008, tratando do seu

RMS 38983 / DF

retorno à Instituição, formalizando-se o Processo nº 00404.007706/2008-15, que foi instruído com vários documentos a respeito, dentre os quais destacou-se o Ofício nº 149/PRSECR, datado de 1º de julho de 2008, da lavra do Senador Efraim Moraes, à época Primeiro Secretário do Senado Federal, por meio do qual comunicou à AGU a devolução do Assistente Jurídico Joarez após ter prestado serviços àquela Casa de Leis;

134.6 esse ofício de apresentação foi uma exigência feita ao indiciado de que houvesse um ato oficial de sua devolução pelo Senado à AGU;

134.7 uma prova de que o servidor esteve cedido informalmente ao Senado após 27/07/2006 é o fato de que teve sua situação enquadrada no citado Ato Regimental, razão pela qual foi aberto o processo administrativo respectivo, resultando na sua notificação para comparecer à AGU em 19/07/2008;

134.8 o citado ofício do Senador Efraim Moraes marca de forma categórica e definitiva a real data em que o indiciado foi devolvido à AGU, que é exatamente 1º/07/2008, quando se apresentou em cumprimento à Carta nº 140-DIRES/CGRHTI/SGAU.'

135. Sobre tais alegações, cumpre dizer o que se segue.

136. De início, há de se esclarecer o equívoco na afirmação de que o indiciado passou para os quadros da Instituição em janeiro de 2004, data em que a AGU assumiu a sua folha de pagamento. São fatos distintos que não se confundem.

137. Isso porque o indiciado ocupa o cargo de Assistente Jurídico e, nessa condição, foi incluído no quadro suplementar da AGU por força do art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 06/09/2001.19 Portanto, desde 2001 passou a integrar os quadros da Instituição e não a partir de janeiro de 2004, data essa que representa tão-somente a absorção da sua folha de pagamento.

138. Equivoca-se também a defesa ao alegar que houve aceitação tácita da cessão informal do indiciado pela AGU

RMS 38983 / DF

apenas porque não foi regularizada a sua permanência no Senado, ou seja, dando a entender que a Administração teria concordado com essa situação irregular.

139. Não é exatamente isso o que aconteceu.

140. Ora, o mérito do pleito de cessão só não foi apreciado em definitivo porque foram verificadas no curso do procedimento respectivo inconsistências nos registros funcionais do servidor, o que NÃO SIGNIFICA DIZER que houve concordância com a sua permanência no Senado. Enfim, o pedido JAMAIS FOI AUTORIZADO TÁCITA OU EXPRESSAMENTE.

141. Outrossim, não se pode esquecer que o período em que o acusado esteve irregularmente à disposição do Senado também está compreendido no raio de apuração deste processo, demonstrando objetivamente que Administração jamais chancelou ou anuiu com a sua cessão.

142. Com efeito, o DESPACHO DECOR/CGU N° 123/2007-JD, de 03 de abril de 2007, que subsidiou a decisão de instauração deste feito pelo Sr. Advogado-Geral da União, foi taxativo ao dizer que 'A FALTA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, POR SI SÓ, EXIGE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR POSSÍVEL ABANDONO DE CARGO.'

143. Ademais, a existência de prévio ato formal de deferimento da Administração é condição necessária para o início da cessão, o que nunca ocorreu no caso concreto. Se mesmo assim o indiciado optou por continuar no Senado Federal de forma irregular, foi por sua conta e risco.

144. De qualquer modo, ainda que admitíssemos a figura da 'aceitação tácita' da cessão pela AGU, essa deixaria de existir no momento em que o servidor parou de prestar serviço ao Senado Federal, a partir de 27/07/2006, quando foi tornada sem efeito a sua última nomeação para o cargo de Assessor Parlamentar.

145. Também não é verdade que o servidor indiciado

RMS 38983 / DF

continuou prestando serviços informalmente àquela Casa Legislativa mesmo após essa data (27/07/2007), como diz a defesa, afirmando, inclusive, que a cessão teria perdurado até 1º de julho de 2008, data em que teria sido apresentado à AGU por meio do Ofício nº 149/PRSECR, da lavra do Senador Efraim Moraes.

146. O referido ofício foi dirigido ao Diretor de RH da AGU e possui o seguinte teor:

Senhor Diretor,

Com meus cumprimentos, comunico a Vossa Senhoria a devolução a esta Advocacia, o Assistente Jurídico JOAREZ GOMES DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 0440153. após ter prestado serviços ao Senado Federal, conforme informações do ex- Senador ANTERO PAES DE BARROS. (grifo nosso)

Cordialmente,

Senador EFRAIM MORAIS

Primeiro-Secretário

147. Ora, como não poderia deixar de ser, em nenhum momento **o ofício dá a entender que o servidor ainda estaria à disposição do Senado até o momento da sua expedição, em 19/07/2008**, pois retrata apenas uma realidade passada, mas precisamente no período em que vigorou o mandato do ex-Senador Antero Paes de Barros, tanto que o referido ofício declara expressamente que foi baseado em informações prestadas pelo próprio ex- Parlamentar.

148. Isso porque **a prova documental constante dos autos revela exatamente que o ex-Senador Antero Paes de Barros desistiu da cessão do servidor ainda no mês de julho de 2006.**

149. Aliás, o próprio indiciado CONFESSOU que esteve **à disposição do Senado Federal SOMENTE ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO DO REFERIDO EX- PARLAMENTAR, ocorrido no mesmo ano de 2006, até porque não foi reeleito.**

150. Confira-se o que declarou o servidor na oportunidade, *in verbis*:

(...) AO TÉRMINO DO MANDATO DO SENADOR,

RMS 38983 / DF

solicitou lotação em Cuiabá, a qual não foi atendida, tendo então solicitado exoneração do cargo.

(...)

Perguntado se se encontra cedido para algum órgão público fora da AGU, respondeu que **PRESTOU SERVIÇO AO SENADO FEDERAL, NO GABINETE DO ENTÃO SENADOR ANTERO PAES DE BARROS NETO. AO TÉRMINO DO MANDATO DO SENADOR, SOLICITOU LOTAÇÃO EM CUIABÁ, a qual não foi atendida, tendo então solicitado exoneração do cargo PERGUNTADO POR QUANTO TEMPO ESTEVE CEDIDO PARA O SENADO FEDERAL, RESPONDEU QUE DESDE 2002 ATÉ O FINAL DO MANDATO DO SENADOR, NO FINAL DE 2006. (...).**" (fls. 226/229 do Apenso IV deste PAD)

151. Essa também é a realidade espelhada no requerimento de restabelecimento de pagamento feito pelo acusado em expediente datado de 05/02/2007, afirmando que teria prestado serviço ao Senador até o fim do respectivo mandato (fls. 2 a 4 do Apenso I, Principal).

152. Portanto, na melhor das hipóteses, a prestação de serviço no Gabinete do ex-Parlamentar só poderia mesmo se estender até o final do respectivo mandato, em dezembro/2006, o que nos leva a concluir pela total inconsistência da alegação contida no Memorial de defesa, pois **CONTRARIA NÃO APENAS A PROVA DOS AUTOS, MAS TAMBÉM O QUE FOI DITO PELO PRÓPRIO SERVIDOR INDICIADO.**

153. Feitos tais apontamentos, é forçoso concluir que a prestação de serviço ao Senado Federal até o dia 19/07/2008 é, no mínimo, fantasiosa e foi alegada tão-somente para encobrir uma realidade mais do que provada e confessada: a partir de 2006 já não existia nem mesmo a figura da cessão informal do Assistente Jurídico Joarez Gomes de Souza, dando ensejo ao início do cômputo do prazo de abandono de cargo, na forma delineada nos itens precedentes.

154. Já a 'devolução' do acusado mediante ofício do

RMS 38983 / DF

Senado Federal expedido somente em 2008 traduziu-se em mera formalidade que não altera a realidade substancial dos fatos. Como dito no Memorial de defesa, essa foi uma exigência da própria Administração, todavia, baseada na presunção de que até aquela data o servidor ainda estivesse trabalhando junto ao órgão cessionário, o que, como vimos acima, não aconteceu no caso analisado nestes autos.

155. Sobre a aplicação ao caso do acusado das disposições do Ato Regimental do Advogado-Geral da União nº 08/200723, há de ser feita a correta e racional leitura dos seus termos. Confira-se:

"(...) Art. 1º Fica vedada a cessão dos ocupantes dos cargos de Advogado da União e Procurador Federal, bem como dos integrantes dos quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, para órgãos não integrantes da estrutura da AGU e de seus órgãos vinculados, ressalvadas as cessões para:

I - órgãos e entidades federais, para o exercício de cargos em comissão de Natureza Especial ou do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, níveis 5 (cinco) e 6 (seis), ou equivalentes;

II - Gabinetes de Ministros do Supremo Tribunal Federal e de Tribunais Superiores; III - Gabinete do Procurador-Geral da República;

IV - Conselhos de Contribuintes Federais; V- Conselho de Recursos da Previdência Social;

VI - Estados, Distrito Federal e Municípios que sejam capitais de Estado ou possuam mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, para o exercício de cargo de Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Município, respectivamente; e

VII Estados, Distrito Federal e Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, para o exercício de cargo ou função de chefia de suas respectivas unidades de representação judicial ou consultoria e assessoramento

RMS 38983 / DF

jurídicos. § 1º Aplica-se às cessões previstas neste artigo o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 2º A cessão prevista no caput será concedida pelo prazo de até um ano, podendo ser renovada no interesse da AGU.

§ 3º O disposto no caput não se aplica às hipóteses de requisição previstas em lei.

Art. 2º Os ocupantes de cargos de Advogado da União, Procurador Federal e dos quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, QUE ESTEJAM CEDIDOS EM DESACORDO com as regras do art. 1º deverão retornar aos seus órgãos de origem até 1º de julho de 2008.

(...)

Art. 4º O presente Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação."

156. Assim, pelo seu artigo 1º ficou vedada a cessão dos membros da AGU para órgãos estranhos à estrutura da AGU, ressalvadas apenas para o exercício das funções nos órgãos mencionados nos seus incisos. Para aqueles que já se encontravam cedidos em locais não mencionados nas exceções, o art. 2º do mesmo normativo previu o retorno à Instituição até o dia 1º de abril de 2008, ou seja, quando em DESACORDO com as novas regras estabelecidas.

157. No caso concreto, como exaustivamente comprovado nos autos, **a cessão do acusado, ainda que tida como informal, já não mais existia desde o dia 27/07/06 ou, quando muito, desde o primeiro dia subsequente ao término do mandato do Senador Antero Paes, em 31/12/06.**

158. Logo, ao tempo da edição do ato em tela, o indiciado **NÃO MAIS** se encontrava à disposição do Senado, motivo pelo qual **não poderia mesmo ser alcançado pela regra do seu artigo 2º, que apenas determinou o retorno daqueles que, NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO, em 17 de dezembro de 2007, ESTAVAM CEDIDOS em órgãos estranhos à AGU.**

RMS 38983 / DF

159. Repetimos a transcrição do citado art. 2º, *in verbis*:

"(...) Art. 2º Os ocupantes de cargos de Advogado da União, Procurador Federal e dos quadros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, QUE ESTEJAM CEDIDOS EM DESACORDO com as regras do art. 1º DEVERÃO RETORNAR AOS SEUS ÓRGÃOS DE ORIGEM ATÉ 1º DE JULHO DE 2008."

160. De qualquer forma, resta evidente o equívoco da defesa ao afirmar que a Administração baixou a citada portaria 'com a especial finalidade de resolver a situação irregular do indiciado', informalmente cedido ao Senado Federal, e de outros na mesma condição.

161. Isso porque a situação de desconformidade tratada no artigo 2º e o consequente retorno ao órgão de origem NÃO RESIDE NA PRECARIIDADE DA CESSÃO EM SI, mas na falta de atendimento aos novos critérios para a CONTINUIDADE DAQUELAS REGULARMENTE DEFERIDAS E QUE ESTAVAM EM CURSO ao tempo da publicação do ato em comento, dentre os quais, o exercício apenas nos órgãos definidos no seu artigo 1º.

162. O que se quer dizer é que o citado Ato Regimental não foi editado para sanar prévias irregularidades da cessão do servidor, mas tão-somente para dar nova definição ao assunto.

163. Pelos motivos acima elencados, não se pode dizer que a convocação do acusado por meio da Carta nº 140-DIRES/CGRHTI/SGAU24 (e a formalização do processo respectivo) importa no reconhecimento inequívoco da Administração de que sua situação estaria enquadrada nas disposições do aludido Ato Regimental AGU nº 08/07, até porque somente no curso deste processo foram de fato aferidas as reais circunstâncias do abandono de cargo, motivo pelo qual **os vários documentos citados no Memorial de defesa não são hábeis a demonstrar minimamente a permanência da cessão ao Senado após a data de 27/07/2006.**

164. Por fim, ainda quanto ao mérito, considerando

RMS 38983 / DF

sobretudo o suporte probatório colhido na instrução, **há de se reconhecer a presente persecução administrativa exclusivamente em relação à falta funcional de abandono de cargo**, afastando, por consequência, a acusação de improbidade administrativa promovida pela comissão na indicição.

165. Nesse contexto, o dolo da conduta reside tão-somente na ausência injustificada ao serviço e não no dano ao erário pela percepção indevida de proventos, cujos valores poderão ser ressarcidos na via administrativa e/ou judicial próprias. Como disse a comissão, no único período de abandono tido como intencional o servidor não estava mais percebendo qualquer remuneração pela Advocacia-Geral da União.

(...) CONCLUSÃO

190. Por todo o exposto, estando formalmente em ordem o presente processo, adotamos em parte as razões constantes do relatório produzido pela Comissão para concluir o seguinte:

190.1 que o Assistente Jurídico JOAREZ GOMES DE SOUZA, Matrícula SIAPE nº 0440153, cometeu a infração de abandono de cargo no período de 27/07/06 a 05/02/07, infração prevista no art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990, ficando sujeito, portanto, à aplicação da pena de demissão, com fundamento no art. 132, II, da referida Lei (itens 91/165) desta Nota);” (grifos nossos).

12. Como se pode ver, a **análise empreendida na seara administrativo-disciplinar deu-se dentro de parâmetros de legalidade e observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório**, havendo resposta fundamentada às questões levantadas pelo servidor durante a persecução disciplinar.

13. Da prova colhida durante o processo administrativo disciplinar e juntada aos autos, elementos de prova documentais cuja apreciação é cabível em mandado de segurança, pode-se extrair as seguintes conclusões, que, a meu sentir, rechaçam os argumentos do recorrente e confirmam o *animus abandonandi*:

RMS 38983 / DF

(i) A pena de demissão do cargo foi aplicada diante da constatação de **abandono de cargo entre 27/06/2006 a 05/02/2007**, o que equivale a 193 (cento e noventa e três) dias de ausência intencional do servidor.

(ii) Mesmo admitindo-se a tese de “cessão informal”, extrai-se dos autos que, **em 27/06/2006, foi publicado o ato tornando sem efeito a nomeação** do servidor no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros, **momento a partir do qual se considera que deveria ter procurado seu órgão de origem, o que não se verificou na espécie.**

(iii) **Somente no dia 05/02/2007, veio o servidor a comunicar que não se encontrava mais a serviço do Senado, passados quase oito meses da publicação do ato que tornou sem efeito a sua última nomeação** como assessor parlamentar.

(iv) Quando veio a procurar o órgão de origem, em 05/02/2007, o fez para tentar reverter a suspensão dos seus vencimentos e para requerer a mudança de sua lotação de Brasília para a cidade de Cuiabá/MT.

(v) **Apresentou, em 19/06/2007, pedido de exoneração do cargo**, o que representa indício de que não mais tinha o desejo de permanecer na instituição. A desistência desse pedido de exoneração somente foi formalizada em 05/05/2008.

(vi) O interesse tardio de entrar em exercício no órgão de origem, inclusive com a impetração de mandado de segurança, somente foi demonstrado quando já devidamente em curso processo disciplinar destinado a apurar falta funcional capaz de resultar em pena de demissão.

(vii) O servidor afirmou, quando ouvido no PAD, que esteve à disposição do Senado Federal somente até o término do mandato do Senador Antero Paes de Barros, momento a partir do qual declarou ter se desligado em definitivo daquela Casa Legislativa para retornar à cidade de Cuiabá/MT, afirmações que contradizem a tese recursal no sentido de que teria permanecido trabalhando informalmente no Senado, mesmo após o encerramento do mandato do parlamentar.

RMS 38983 / DF

(viii) Mesmo que se admita, por hipótese, que tenha permanecido trabalhando no Senado Federal após 27/06/2006, data em que publicado o ato que tornou sem efeito sua última nomeação no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros, **há que se destacar que o mandato do referido parlamentar cessou em 31/12/2006, motivo pelo qual, mesmo nessa hipótese, ainda assim teriam transcorridos mais de 30 dias consecutivos de ausência ao serviço até o dia 05/02/2007, caracterizando o abandono de cargo.**

(ix) No Processo Administrativo Disciplinar nº 00406.000362/2007-12, que apurou a prática de advocacia fora das atribuições institucionais, o servidor foi punido com a pena de suspensão por 90 (noventa) dias.

(x) Afirmou, durante instrução em PAD, possuir escritório profissional de advocacia em Cuiabá/MT há 06 (seis) anos.

(xi) O Ato Regimental nº 8/2007 não trata da situação do indiciado, que se encontrava ilegalmente ausente de seu órgão de lotação, mas referia-se a todos os membros da AGU regularmente cedidos.

14. A partir da análise da impetração na origem, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora recorrido, manteve as conclusões alcançadas no PAD, apontando, no acórdão recorrido, não ter havido *“demonstração de direito líquido e certo a ser tutelado na via do mandado de segurança”* e que *“o ato de demissão foi precedido do processo administrativo disciplinar, a fim de que fosse verificada toda a situação funcional do agravante”*. Foi assentada, ainda, no aresto, a assertiva de que o mandado de segurança *“não possui campo para cotejo de matéria fático-probatória, demandando, ainda, para conhecimento, a comprovação de plano do direito alegado”*.

15. Pois bem. Vejo que as conclusões alcançadas pelo Superior Tribunal de Justiça se coadunam com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ainda, a análise das diversas etapas do processo administrativo disciplinar permite verificar o respeito, pela

RMS 38983 / DF

comissão processante e pela autoridade julgadora, ao devido processo legal, conforme o vem concebendo esta Suprema Corte.

16. Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal assenta a impossibilidade de reexaminar, em mandado de segurança, matéria fática apreciada em processo administrativo disciplinar, resumindo-se, eventual revisão judicial, ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do *due process of law*. Transcrevo julgados que sintetizam a posição da Corte:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do *due process of law*. Precedentes.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a vedação constitucional de acumular cargos, funções e empregos remunerados estende-se aos juízes classistas, sendo que a renúncia à remuneração por uma das fontes, mesmo se possível, não teria o condão de afastar a proibição. Precedente.

3. A CLT, em seus artigos 645, 663, 726, 727 e 728, não autoriza o servidor público sindicalizado, no exercício de função de direção, a afastar-se do seu cargo efetivo após o indeferimento da licença para tratar de interesse particular.

4. A estabilidade provisória de representante sindical, prevista no artigo 8º, VIII,

RMS 38983 / DF

da Carta da República, é assegurada aos empregados celetistas e não ao servidor estatutário. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(RMS nº 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/03/2003, p. 04/04/2003; grifos nossos).

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA– AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘*writ*’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.”

(RMS nº 35.745-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

17. Quanto à tese recursal de que não se poderia cogitar na aplicação da pena de cassação, *“visto que o implemento das condições para se aposentar [tempo de serviço + tempo de contribuição] ocorreu antes da aplicação da pena de demissão”*, observo que esta Suprema Corte já se pronunciou, em diversas oportunidades, a respeito da constitucionalidade de sua aplicação. Nesse sentido:

“EMENTA: I. Cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão (L. 8.112/90, art. 134): constitucionalidade, sendo irrelevante que não a preveja a Constituição e improcedente a alegação de ofensa do ato jurídico perfeito. II. Presidente da República:

RMS 38983 / DF

competência para a demissão de servidor de autarquia federal ou a cassação de sua aposentadoria. III. Punição disciplinar: prescrição: a instauração do processo disciplinar interrompe o fluxo da prescrição, que volta a correr por inteiro se não decidido no prazo legal de 140 dias, a partir do termo final desse último. IV. Processo administrativo-disciplinar: congruência entre a indicição e o fundamento da punição aplicada, que se verifica a partir dos fatos imputados e não de sua capitulação legal.”

(MS nº 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 06/03/2002, p. 12/04/2002; grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. **O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência** (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

(ARE nº 1.368.701-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
2. Direito administrativo. **Cassação de aposentadoria por**

RMS 38983 / DF

prática de infração disciplinar. Constitucionalidade.

Precedentes 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.”

(ARE nº 1.322.693-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos).

18. Nesse passo, não há que se falar em irregularidade na transformação da pena de demissão na de cassação de aposentadoria, tendo em vista que o servidor somente alcançou a aposentadoria por estar acobertado por medida liminar que, por sua própria natureza, tem caráter precário e provisório, e decai em caso de julgamento final que desacolha o pedido autoral.

19. Em conclusão, observo que a intenção do recorrente é a de obter o reexame das provas acostadas aos autos para afastar a pena aplicada de demissão, convertida em cassação de aposentadoria, providência inadmissível em sede de mandado de segurança.

20. Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo, **nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.**

É como voto.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA

Relator

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.983

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ANDRÉ MENDONÇA

RECTE.(S) : JOAREZ GOMES DE SOUZA

ADV.(A/S) : LENINE POVOAS DE ABREU (17120/O/MT)

RECDO.(A/S) : UNIÃO

PROC.(A/S) (ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Após o voto do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, diante da ausência de direito líquido e certo, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Segunda Turma, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.

Composição: Ministros André Mendonça (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques.

Hannah Gevartosky
Secretária

13/11/2023**SEGUNDA TURMA****RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.983 DISTRITO
FEDERAL**

RELATOR	: MIN. ANDRÉ MENDONÇA
REDATOR DO	: MIN. GILMAR MENDES
ACÓRDÃO	
RECTE.(S)	: JOAREZ GOMES DE SOUZA
ADV.(A/S)	: LENINE POVOAS DE ABREU
RECDO.(A/S)	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

VOTO – VISTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de recurso ordinário interposto por Juarez Gomes de Souza contra acórdão (eDOCs 114 e 115) da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do qual o referido órgão colegiado referendou decisão monocrática anterior que houvera denegado a segurança pleiteada (eDOC 60).

Na espécie, cuidam os autos de mandado de segurança ajuizado contra ato do Advogado-Geral da União que demitiu o impetrante do cargo de assistente jurídico, em virtude da prática, apurada em processo administrativo disciplinar (PAD), de abandono do cargo por 193 (cento e noventa e três) dias no período compreendido entre 27.7.2006 e 5.2.2007 (Lei 8.112/1990, arts. 132, II e 138).

Por ocasião da impetração, em 23.10.2009, o processo administrativo disciplinar encontrava-se em fase final de julgamento, tendo o mandado de segurança se voltado contra a própria instauração e o processamento do processo administrativo disciplinar, assumindo a feição de writ preventivo que objetivava obstar a prática do ato demissório. Poucos dias depois, entretanto, sobreveio a Portaria-AGU n. 1.603, de 3 de novembro de 2009, por meio da qual restou aplicada ao impetrante a pena de demissão em virtude do alegado abandono do cargo, antes mesmo que a liminar pleiteada nos autos houvesse sido apreciada.

RMS 38983 / DF

Após colhidas informações junto à autoridade coatora, sobreveio, em 13.10.2009, decisão por meio da qual o Ministro Jorge Mussi, então relator do feito no STJ, concedeu medida liminar *“para suspender os efeitos da Portaria n. 1.603, de 3/11/2009, do Advogado Geral da União, até o julgamento do mérito deste writ e, em consequência, reintegrar o impetrante no cargo do qual foi demitido”* (eDOC 23).

Por força de tal decisão, o impetrante foi reintegrado aos quadros da Advocacia Geral da União (AGU), órgão perante o qual prestou serviços regularmente até 21.12.2020, data em que lhe foi concedida aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, haja vista o cumprimento dos requisitos legais para tanto (Portaria-AGU n. 146/2020 – eDOC 63, pp. 2-3).

Em 18.3.2021, entretanto, sobreveio decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que assumiu a relatoria do feito no STJ, tornando sem efeito a decisão liminar anteriormente concedida e denegando a segurança pleiteada (eDOC 60). Ato contínuo, a Advocacia Geral da União, por intermédio da Portaria-AGU n. 172/2021, tornou sem efeito o ato que houvera concedido aposentadoria voluntária ao impetrante, convertendo, ao fim e ao cabo, a pena de demissão – que lhe foi aplicada em 2009 e posteriormente suspensa por decisão judicial – na de cassação de sua aposentadoria (eDOC 120, p. 26).

Após o manejo de uma série de recursos, a decisão monocrática que denegou a segurança veio a ser referendada pela 3ª Seção do STJ, o que se deu por meio do aresto impugnado (eDOCs 114 e 115).

Em seu recurso ordinário (eDOC 120), o impetrante alega, em síntese, não estarem presentes na espécie os requisitos necessários à caracterização do abandono de cargo, inexistindo (i) dano ao erário, (ii) prejuízo para a Administração e, sobretudo, (iii) a caracterização de intenção do servidor em abandonar o emprego, pressuposto para a aplicação da penalidade nos termos do art. 138 da Lei 8.112/1990.

Assim sendo, aduz que a União teria violado seu direito líquido e certo ao aplicar-lhe a pena de demissão, posteriormente efetivada mediante a cassação de sua aposentadoria.

RMS 38983 / DF

O julgamento do presente feito iniciou-se na sessão virtual ocorrida entre 23.6.2023 e 30.6.2023, ocasião em que o eminente Relator, Ministro André Mendonça, apresentou voto no sentido da negativa de provimento ao recurso ordinário. Logo em seguida pedi vista dos autos para mais detidamente analisar as particularidades do caso concreto.

**I – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL À
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO**

Com todas as vênias à posição defendida pelo eminente Relator, entendendo ser o caso de dar provimento ao recurso ordinário, haja vista a não caracterização, nos termos do art. 138 da Lei 8.112/1990, de elemento subjetivo essencial para a constatação da infração funcional que lhe foi imputada, qual seja, a intenção do impetrante de abandonar o cargo que ocupava.

Com efeito, tenho que a situação de indefinição e desordem administrativa em que se insere o período de “cessão informal” do impetrante ao Senado não lhe pode ser de todo atribuída, estando documentados no PAD, ao contrário, diversos episódios que demonstram o seu inequívoco interesse na regularização de sua situação funcional (incompatíveis, portanto, com o intuito de abandonar o cargo).

De início, destaco que o exame dos assentamentos funcionais do impetrante revela histórico de serviço bastante conturbado, com ingresso no serviço público federal antes de 1988 e passagem por diversos órgãos da administração pública federal, grande parte dos quais já à época em processo de extinção e há muito extintos. Apesar de aparentemente caótica, a situação não destoia muito do que se observava dentre os servidores da época, caracterizada pela sucessão de reformas administrativas orientadas pelos propósitos de modernização da administração pública federal e de adequação aos novos ditames introduzidos pelo art. 37 da Constituição.

Toda essa trajetória funcional abundante em alterações de lotação e

RMS 38983 / DF

de cargo culminou com a redistribuição do impetrante para a AGU em 2001 e com extenso período de “*cessão informal*” do impetrante ao Senado – período no qual, ao final, se verificou o intervalo temporal de alegado abandono de cargo objeto do PAD discutido nestes autos.

Para ilustrar esse último período após a redistribuição do impetrante à AGU, transcrevo trecho recuperado pelo eminente Ministro Relator do relatório final da comissão de inquérito do PAD, no qual a comissão processante reproduz sua visão acerca do histórico funcional do impetrante (eDOC 6, pp. 21/26):

“a) Quanto ao histórico funcional do acusado: [...]

- **06.set.2001** – o servidor é redistribuído do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43/01, não havendo notícia de que tenha tido exercício em qualquer unidade da AGU;

- **nov.2002** – início do exercício irregular do acusado no Senado Federal, cf. Ofício nº 004/2004 do Senador Antero Paes de Barros (fls. 02 do Anexo I do Apenso I, fls. 01 do Apenso IV do Anexo IV e fls. 51 do Anexo II do Apenso I);

- **01.jan.2004** – a AGU finalmente assume a folha de pagamento do servidor (fls. 12, dos autos principais do Apenso I; fls. 112 e 131 do Anexo I do Apenso I);

- **07.jan.2004** – Ofício nº 004/2004 do Senador Antero Paes de Barros: primeira solicitação formal do Senado Federal à COGEP/MP para que o acusado fosse cedido (fls. 02 do Anexo I do Apenso I, fls. 01 do Apenso IV do Anexo IV e fls. 51 do Anexo II do Apenso I), sendo que o ofício acabou sendo remetido à AGU uma vez que agora o servidor já não mais pertencia aos quadros do Ministério do Planejamento;

- **16.mar.2004** – Informação nº 133-CGRH/DRHTI/SGAGU, em resposta ao Ofício do Senador Antero Paes, estabelecendo as condições para cessão ao Senado (art. 93, inciso I, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.112/90), isto é, somente para assumir cargo em comissão, às fls. 29 do Anexo IV do Apenso IV e às fls. 31 do Anexo I do Apenso I;

RMS 38983 / DF

- **25.mar.2004** – despacho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, informando as mesmas condições, citando ainda o art. 3º, inciso II, do Decreto nº 4.050/01 e o Ofício-circular nº 32/2000 (fls. 64 do Anexo I do Apenso I);

- **03.mai.2004** – Senado Federal formaliza pela primeira vez a nomeação do acusado para o cargo em comissão de Assistente Parlamentar (símbolo AP-6), porém antes de a AGU autorizar a cessão; os atos são tornados sem efeito, diante da inexistência formal do ato de posse, e reeditados sucessivamente enquanto a autorização não é concedida, até que o Senador Antero Paes desiste da nomeação em jul.2006 (fls. 165- 200 dos autos principais do Apenso IV);

- **13.mai.2004** – Senado Federal informa à AGU que, para fins de cessão, o servidor seria nomeado para o cargo em comissão de Assistente Parlamentar (símbolo AP-6) no Gabinete do Senador Antero Paes (fls. 56-60 do Anexo I do Apenso I e fls. 54-59 do Anexo IV do Apenso IV), sendo que, no entanto, já havia sido nomeado à revelia do órgão de origem;

- **09.nov.2004** – frequência do acusado no Senado Federal é confirmada até out.2004 (fls. 73 dos autos principais deste PAD), apesar de suas nomeações irregulares terem continuado até jul.2006;

- **22.fev.2005** – Nota DECOR nº 10/05-MMV (fls. 127-135 do Anexo I do Apenso I), firmando o entendimento da necessidade de regularizar a situação funcional antes da cessão, comprovando que a cessão nunca chegou a ser autorizada e, portanto, nunca ocorreu formalmente;

- **jun.2005** – pagamento do servidor suspenso pela AGU por meio do Memorando nº 430/DRHTI/SGAGU, de 1º de junho de 2005 (fls. 93 do Apenso IV, anexo II);

- **27.jul.2006** – É publicado o Ato do Diretor-Geral do Senado nº 1509 /2006; tornando sem efeito as nomeações do servidor no Senado Federal, diante da desistência do senador Antero Paes em virtude da não autorização da cessão pela AGU (fls. 166 e 180-181 do Apenso IV).

- **05.fev.2007** – requerimento de JOAREZ GOMES DE

RMS 38983 / DF

SOUZA solicitando o restabelecimento do pagamento e sua lotação na PU/MT, em Cuiabá, ou outro órgão de execução da AGU naquele Estado, vinte meses após ter seu pagamento suspenso (fls. 02-04 dos autos principais do Apenso I).

- **19.jun.2007** – requerimento de JOAREZ GOMES DE SOUZA solicitando a sua exoneração do cargo de Assistente Jurídico, bem como a desistência do requerimento anterior (fls. 14 dos autos principais do Apenso IV);

- **05.mai.2008** – requerimento de JOAREZ GOMES DE SOUZA solicitando o cancelamento de seu pedido de exoneração (fls. 311-312 do presente PAD);

- **26.mar.2009** – retorno do acusado ao seu regular exercício, com designação de sua lotação no Gabinete do Advogado-Geral e exercício na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde (fls. 597 dos autos principais deste PAD), sendo este seu primeiro exercício regular desde que redistribuído para a AGU; a definição do local de exercício se deu por provocação do próprio servidor interessado mediante requerimento formulado em 19.fev.2009 e autuado sob nº 00400.001878 /2009-04.

Em face de tal sucessão de eventos e dos elementos colhidos durante o processo, concluiu a comissão processante pela caracterização de abandono de cargo no período de 193 (cento e noventa e três) dias compreendido entre 27.7.2006 e 5.2.2007. A primeira de tais datas (27.7.2006) corresponde ao dia seguinte à edição, pelo Diretor-Geral do Senado do Ato n. 1509/2006, que tornou sem efeito a última nomeação do impetrante para o cargo de Assessor Parlamentar, ao passo que a segunda (5.2.2007) corresponde à data do requerimento do impetrante se reapresentando à AGU após o término de seu período de trabalho no Senado. Sobre o tema, constou no relatório final da comissão de inquérito do PAD, em especial quanto à caracterização da intenção do impetrante de abandonar o cargo que ocupava, o que segue (eDOC 6, pp. 28/42 – grifo nosso):

RMS 38983 / DF

7º. Em 2001 o acusado já estava redistribuído para os quadros da AGU e, apesar da incerteza nos autos de ter estado ou não em exercício desde 1992 e de onde seria este exercício até seu ingresso na AGU, **a partir de novembro de 2002 tal local de exercício já é certo e determinado, qual seja, o Senado Federal (vide histórico funcional retro)**. No entanto, também se trata de exercício irregular, em virtude de 'cessão informal', não amparada por qualquer ato da Advocacia- Geral da União.

8. **Apesar dos indícios, não existe prova direta do animus abandonandi do servidor durante o período em que esteve informalmente cedido ao Senado Federal, até porque existiram atos de nomeação para cargo em comissão entre mai.2004 a jul.2006, embora tal nomeação jamais tenha sido autorizada pela AGU e a primeira nomeação tenha ocorrido à revelia do órgão de origem**. Apesar de não haver comprovantes de frequência no Senado após out. 2004, o servidor foi nomeado sem autorização da AGU até 26.jul.2006, quando o Senador Antero Paes finalmente desistiu da cessão. Seu pagamento foi suspenso na AGU em jun. 2005, mas somente reclamou de tal medida mais de um ano após a suspensão do salário, quando também parou de receber pelo Senado Federal. **Portanto, pelo menos até jun.2006 não se pode afirmar com segurança que o servidor não tinha a intenção de abandonar o cargo, apesar de injustificadamente faltoso, dada a irregularidade de sua situação**.

9º. A partir de 27.jul.2006, contudo, é incontroversa a sua intenção de abandonar o cargo, pois, além de já estar sem receber seu pagamento sem qualquer insurgência contra tal suspensão, sua nomeação para o cargo no Senado Federal foi tornada sem efeito definitivamente, e mesmo assim não retornou ao seu órgão de origem (AGU), nem sequer manifestou qualquer interesse neste sentido até fev.2009, já no curso do presente PAD, quando solicitou a definição de alguma unidade para ter exercício (processo nº 00400.001878/2009- 04), ou pelo menos até 05.fev.2007, quando requereu o restabelecimento de seu pagamento (fls. 02-04 dos autos

RMS 38983 / DF

principais do Apenso I). [...]

110. No que tange ao período a partir de 27.jul.2006, no entanto, há nos autos elementos suficientes que permitem concluir pela intencionalidade do indiciado em cometer as faltas injustificadas nas quais incorreu.

111. A rigor, a própria permanência no Senado Federal sem a autorização da AGU já poderia ensejar a caracterização do dolo do servidor em cometer a transgressão disciplinar a ele imputada, se considerarmos que a insistência em permanecer em uma situação ilegal no Senado enquanto sua cessão não era autorizada possa caracterizar uma clara intenção de colocar seu cargo em segundo plano em relação a seus interesses pessoais ao ponto de abandonar sua função.

112. Todavia, considerando as circunstâncias específicas que permeiam sua situação funcional desde 1992, tal argumento cede diante do fato de que a situação irregular do servidor pode mesmo ter tido origem na desorganização administrativa que o levou a não ter local de exercício definido durante anos nos órgãos onde esteve enquadrado após seu aproveitamento. Em síntese, ainda não há prova inequívoca da intenção de abandonar o cargo até a cessação de suas nomeações no Senado Federal, em 27.jul.2006 (fls. 166 e 180-181 do apenso IV).

113. Tal intenção, porém, é inequívoca a partir de tal momento, pois nesta época o indiciado já estava com o pagamento suspenso pela AGU (fls. 93 do Apenso IV, anexo II) e, mesmo assim, **não buscou retornar ao serviço, pelo menos até 05.fev.2007, quando requereu o restabelecimento de seu pagamento (fls. 02-04 dos autos principais do Apenso I). Não há como se alegar, durante tal período, que ainda buscava uma colocação no serviço público, pois já tinha conhecimento de que estava formalmente lotado na AGU e, mesmo após o término de sua 'cessão informal' ao Senado e a suspensão do pagamento, não buscou manter qualquer contato com seu órgão de origem a fim de retornar ao serviço.** Ao contrário, permaneceu atuando na advocacia privada, já comprovada em

RMS 38983 / DF

outro PAD (Apenso IV) e pela qual foi condenado disciplinarmente. **Caracterizado, assim, de forma inequívoca, um período de 193 dias de faltas intencionais sem justificativa, entre 27.jul.2006 e 05.fev.2007.**

Posteriormente, tais conclusões foram acolhidas e corroboradas pela Corregedoria-Geral da AGU, por meio da Nota Técnica-CGAU/AGU n. 141/2009, em que constou o que segue (eDOC 9, pp. 1/47 – grifo nosso):

63. Por oportuno, alguns esclarecimentos adicionais sobre o período em que o servidor esteve cedido de forma NÃO AUTORIZADA ao Senado Federal devem ser feitos, pois, conforme dito no item 42 supra, **esteve prestando serviço de forma irregular como assessor do Senador Antero P. de Barros entre NOVEMBRO /2002 A 26/07/2006.**

64. Com efeito, por meio de ofício datado de 07/01/2004 (fls. 02 e seguintes do Anexo I do Apenso I), dirigido ao Coordenador de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, o aludido Senador comunica que o Sr. JOAREZ GOMES DE SOUZA esteve **prestando serviço na sua assessoria parlamentar e com frequência devidamente atestada desde novembro de 2002 até 07/01/2004.** Em seguida, o MPOG remeteu tal expediente à Advocacia-Geral da União informando que a referida cessão NÃO HAVIA SIDO FORMALIZADA.

65. Essa parece ser mais uma possível incongruência da certidão citada no item 58 desta Nota, que atesta a frequência normal do servidor até o final de 2003, inobstante o fato de que desde o mês de novembro de 2002 esteve INFORMALMENTE cedido ao Senado Federal.

66. Ao que parece, a formalização do pedido de cessão à AGU somente ocorreu em março de 2004, conforme Ofício nº 062/2004, da Presidência do Senado Federal (fl. 34 do Anexo I do Apenso I).

67. No entanto, a partir do recebimento do pleito de cessão, foi constatada a imprecisão nas informações relativas à situação funcional do servidor, fazendo com que processo de

RMS 38983 / DF

cessão tramitasse na Administração Pública por tempo razoável ao deslinde da questão.

68. Ao final, diante das fundadas dúvidas quanto à frequência do servidor ao longo dos anos, a análise de mérito do pedido de cessão restou prejudicada, pois havia a necessidade de se estabelecer, com precisão, o período em que efetivamente esteve no exercício das atribuições do seu cargo.

69. A par disso, **mesmo não tendo sido decidido o pedido de cessão pela Administração**, o Senado Federal, desde 03/05/04, promoveu uma série de nomeações que foram sendo tornadas sem efeito e reeditadas sucessivamente enquanto se aguardava o desfecho da cessão. A última nomeação foi tornada sem efeito pelo Ato do Diretor-Geral do Senado nº 1.509, publicado no dia 27/07/06, conforme documento de fls. 180/181 do Apenso nº 4, in verbis: [...]

71. Feitos os apontamentos acima, especificamente em relação ao período compreendido entre janeiro/2004 até 26/07/2006, é razoável admitir que **o fato de não ter sido apreciado o mérito da cessão**, por si só, já impede o abono dos dias de remuneração em que o servidor não esteve à disposição da Advocacia-Geral da União, de modo que, salvo melhor juízo, a Administração deve ser ressarcida pela remuneração paga indevidamente no período considerado, ao menos até o mês de junho de 2005, data em que foi suspenso o pagamento dos respectivos vencimentos, conforme consta do Memorando nº 430/DRHTI/SGAU, de 1º de junho de 2005,¹² a partir da constatação de irregularidades na sua situação funcional.

72. Todavia, não obstante as ausências injustificadas ao serviço, como posto acima, há de se concluir que não há provas inequívocas quanto a um dos requisitos da infração de abandono de cargo, qual seja, a intencionalidade na conduta do acusado.

73. **Com efeito, apesar da irregularidade de todo o procedimento, o pedido formal de cessão já estava sob o crivo da Administração da Advocacia-Geral da União desde o início de 2004, oportunidade em que foi constatada a existência de**

RMS 38983 / DF

várias inconsistências na vida funcional do interessado, que estava pendente de regularização. [...]

78. Em suma, para fins de caracterização da infração do art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990, é possível concluir o seguinte:

78.1 em face dos fundamentos contidos nos itens 51 a 62 acima, não merece prosperar o período de abandono considerado na indicição que vai de 10 de abril de 1992 a até dezembro de 2003, pois tal lapso temporal encontra-se abrangido pelas certidões de tempo de serviço emitidas pela própria Administração (1988 a 2003), que presumem-se verdadeiras até prova em contrário, em que pese os vários indícios de irregularidades quanto aos dados ali contidos;

78.2 o tempo em que o servidor esteve prestando serviço ao Senador Antero Paes sem qualquer pedido de cessão formalizado (novembro/2002 a dezembro/2003), embora caracterizado pela ilegalidade, não pode ser computado como falta ao serviço, pois, da mesma forma, tal período também está abrangido pelas certidões expedidas pela Administração;

78.3 já pelas razões esposadas nos itens 64/77 desta Nota Técnica, deve ser acatado o entendimento da comissão de que não ficou bem claro o dolo nas faltas injustificadas relacionadas ao período em que o Senado Federal aguardou o trâmite do pedido FORMAL de cessão do servidor junto à AGU (07/01/2004 a 26/07/2006), pois, apesar do mérito do pedido não ter sido apreciado, havia ainda o interesse do Senado em colocá-lo à disposição daquela Casa de Leis.

79. De outra banda, concluiu a comissão pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias

RMS 38983 / DF

consecutivos desde que foi publicado o ato tornando sem efeito a sua nomeação no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros, fato esse ocorrido em 27/07/2006. [...]

90. Para a melhor compreensão da questão, recapitulamos o histórico dos fatos ocorridos.

90.1 conforme dito nos itens anteriores, desde o ano de 2004 o Senado tentava junto à Advocacia-Geral da União a cessão do Assistente Jurídico Joarez Gomes de Souza, como fito de nomeá-lo para o cargo de assessor Parlamentar daquela Casa Legislativa.

90.2 em face de inconsistências na vida funcional do referido servidor, **o mérito do pedido não chegou a ser examinado pela Administração.** Não obstante isso, sem qualquer autorização ou deferimento por parte do órgão cedente, o Senado promoveu a nomeação do servidor sucessivas vezes nos dois anos subsequentes (2004 a 2006), todas tornadas sem efeito na medida em que se esgotava o prazo para a posse estabelecido na Lei nº 8.112, de 1990.

90.3 assim sendo, o Senador Antero Paes de Barros desistiu definitivamente da cessão ainda em 2006.

90.4 em consequência, por meio do Ato nº 1509/2006, de 26/07/2006, publicado no dia 27/07/2006, do Diretor-Geral do Senado Federal, a última nomeação do servidor para exercer cargo comissionado naquela Casa de Leis foi tornada sem efeito.

90.5 somente em 05/02/2007, quase 08 (oito meses) após a publicação do ato que tornou sem efeito a sua última nomeação no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros e decorridos quase 2 (dois) anos desde a suspensão do seu pagamento,

RMS 38983 / DF

em junho/2005, vem o servidor requerer junto à Instituição o restabelecimento da remuneração do cargo de Assistente Jurídico, mesmo sabendo da ausência de qualquer prestação de serviço decorrente de suas funções jurídicas no âmbito da AGU. Por fim, no mesmo expediente, solicitou o interessado que sua lotação fosse fixada na cidade de Cuiabá/MT (fls. 2 a 4 do Apenso I, Principal).

91. Diante desses fatos devidamente comprovados nos autos e considerando o tempo decorrido entre os dias 27/06/2006 e 05/02/2007, concluiu a comissão que, neste período de 193 (cento e noventa e três) dias, ficou evidenciada a ausência intencional do indiciado.

92. Manifestamo-nos de acordo com esse entendimento, pois as evidências colhidas na instrução do feito demonstram claramente essa situação, senão vejamos.

93. Como bem demonstrado nos autos, a 'prestação de serviço' do servidor no Gabinete do Senador Antero Paes de Barros cessou definitivamente em 27/07/2006, por desistência da sua nomeação para ocupar cargo naquela Casa de Leis.

94. Pois bem. Finalizada essa cessão informal e mesmo com o pagamento alusivo ao cargo de Assistente Jurídico suspenso desde julho/2005, ao invés de apresentar-se de imediato para exercer de fato suas atribuições junto à Advocacia-Geral da União, preferiu o acusado, no entanto, estabelecer-se na Cidade de Cuiabá onde confessadamente possuía escritório profissional para dedicar-se ao exercício de advocacia fora das atribuições institucionais, inclusive contra a União e suas Autarquias, o que constitui flagrante inobservância do impedimento estabelecido no art. 30, inciso I, do Estatuto da OAB.

95. Se o servidor indiciado não quis deliberadamente abandonar o cargo, no mínimo assumiu o risco dessa conduta ao não retornar de imediato ao órgão de sua lotação tão logo deixou de 'prestar serviço' ao Senado Federal. Nem mesmo se

RMS 38983 / DF

apresentou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde tinha sua lotação antes de ser redistribuído à AGU. [...]

99. Outra evidência que demonstra o descaso em relação à Instituição reside no fato de que **o acusado não se dignou a comunicar que a sua última nomeação como Assessor Parlamentar havia sido tornada sem efeito desde 27/07/2006, momento a partir do qual não foi apresentado qualquer indicativo no sentido de que o Senado ainda tinha algum interesse por sua cessão.**

100. Ao contrário, a prova documental revela que o então Senador Antero Paes de Barros DESISTIU de nomear o servidor como seu assessor Parlamentar ainda em 2006. É o que consta do Ofício nº 097/07-DGER, de 20/08/07, do Diretor-Geral do Senado (fl. 165 do presente processo disciplinar, integrante do Apenso 4 deste PAD), o qual transcrevemos, in verbis: [...]

101. Por parte do Senado Federal, conforme expressamente consignado na primeira parte do expediente acima transcrito, essa informação só foi prestada após formal solicitação do Presidente da Comissão designada nos autos do Processo nº 00406.000362/2007-12, que apurou a advocacia privada por parte do mesmo acusado, que foi punido com a pena de suspensão.

102. Por parte do acusado, somente no dia 05 de fevereiro de 2007, veio o mesmo a comunicar que não se encontrava mais a serviço do Senado, isso passados quase oito meses da publicação do ato que tornou sem efeito a sua última nomeação como assessor Parlamentar e, ainda assim, com objetivos outros que não o alertar a Administração acerca da sua real situação.

103. Portanto, **TÃO LOGO findou a sua disponibilidade no Senado, em 27/07/09,** deveria o servidor ao menos procurar o seu órgão de lotação na AGU para entrar em exercício no cargo de Assistente Jurídico do quadro suplementar da Instituição. Mas assim não procedeu, incidindo, via de

RMS 38983 / DF

consequência, na infração de abandono de cargo entre 27/06/06 a 05/02/07.

104. Ainda que não tivesse havido a desistência da cessão em meados de 2006, a permanência do Assistente Jurídico Joarez Gomes de Souza no Senado Federal só poderia se justificar até o término do mandado (SIC) do ex-Senador Antero Paes de Barros, QUE FINDOU EM 31/12/2006, momento a partir do qual o próprio servidor declarou ter se desligado em definitivo daquela Casa Legislativa para retornar à cidade de Cuiabá/MT, como se verá mais adiante.

105. Mesmo na hipótese acima aventada, ainda assim teriam transcorridos mais de 30 dias consecutivos de ausência ao serviço até o dia 05/02/2007, caracterizando o abandono de cargo. [...]

111. Preliminarmente, há de se destacar que o caso de abandono do indiciado não pode simplesmente ser comparado aos demais casos, dado o contexto peculiar em que está inserido. Essa constatação se dá por um fato documentalmente comprovado nos autos: A VALIDADE DA CESSÃO DO SERVIDOR, EMBORA NÃO APRECIADO O PEDIDO FORMALIZADO A ESSE RESPEITO, JÁ HAVIA SE ENCERRADO DESDE 27/07/2006, QUANDO O SENADOR DESISTIU DE NOMEÁ-LO COMO SEU ASSESSOR.

112. Logo, não se está discutindo a intencionalidade do abandono durante o tempo em que tramitou o pedido de cessão, que teve início em 2004, mas sim, no período iniciado com a data em que foi tornada sem efeito a última nomeação do servidor por ato do próprio Senado, em 27/07/06, ou seja, quando não se encontrava mais prestando serviços àquela Casa. Isso é o que demonstra a farta prova produzida pela comissão da qual a defesa não logrou êxito em refutar.

113. Tanto é que, entre janeiro/2004 até o dia imediatamente anterior à publicação do ato pela Direção-Geral do Senado, em 26/07/2006, a própria comissão reconheceu a deficiência de maiores elementos configuradores do dolo, não obstante a ausência de justificativa

RMS 38983 / DF

legal para as ausências ao serviço por parte do acusado, já que não poderia trabalhar em local para o qual não havia sido previamente autorizado pela Administração competente. '[...]

CONCLUSÃO

190. Por todo o exposto, estando formalmente em ordem o presente processo, adotamos em parte as razões constantes do relatório produzido pela Comissão para concluir o seguinte:

190.1 que o Assistente Jurídico JOAREZ GOMES DE SOUZA, Matrícula SIAPE nº 0440153, cometeu a infração de abandono de cargo no período de 27/07/06 a 05/02/07, infração prevista no art. 138 da Lei nº 8.112, de 1990, ficando sujeito, portanto, à aplicação da pena de demissão, com fundamento no art. 132, II, da referida Lei (itens 91 /165) desta Nota);

Os excertos acima transcritos, apesar de extensos (e em grande parte já recuperados no voto do eminente Relator), mostram-se essenciais para revelar os fundamentos do raciocínio adotado pela Administração na aplicação da penalidade de demissão combatida pelo mandado de segurança ora em apreciação.

Com efeito, as passagens acima reproduzidas, em especial os trechos destacados, demonstram que a AGU partiu das seguintes premissas para motivar a aplicação da penalidade:

Premissa 1 – Sem deixar de considerá-la ilegal, a AGU reconhece ter havido “*cessão informal*” do impetrante ao Senado, com prestação de serviços junto ao gabinete do então senador Antero Paes de Barros desde novembro de 2002, não sendo possível atestar a intencionalidade de eventual abandono de cargo durante o período em que o impetrante prestava serviços ao Senado, mesmo porque inequívocas as tentativas de regularização da cessão e incontroverso o fato de que a própria AGU não decidiu o pedido de cessão então realizado pelo Senado.

Premissa 2 – A prestação de serviços ao Senado, contudo, teria cessado definitivamente em 27/6/2006, data de publicação do ato que tornou sem efeito o último ato de nomeação do impetrante ao cargo de

RMS 38983 / DF

Assessor Parlamentar (AP-8).

Premissa 3 – O impetrante somente se reapresentou à AGU em 5/2/2007, data em que requereu o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos e sua lotação em Cuiabá/MT.

Conjugando essas três premissas, a Administração concluiu pela ocorrência de abandono de cargo, nos termos do art. 138 da Lei 8.112/1990, no intervalo compreendido entre 27.7.2006 e 5.2.2007 – período em que o impetrante, após ter supostamente encerrado a prestação de serviços junto ao Senado, teria demorado, por desídia e opção deliberada, 193 (cento e noventa e três) dias para se reapresentar ao seu órgão de origem.

Nada obstante, ainda que a primeira e a terceira premissas sejam incontroversas, o mesmo não pode ser dito quanto à assertiva de que a “*cessão informal*” e a prestação de serviços por parte do impetrante junto ao Senado teria cessado definitivamente em 27/6/2006. **Tal conclusão, além de disputada pelo impetrante, destoa do acervo documental produzido nos autos do processo administrativo.**

Quanto ao ponto, sustenta o impetrante que a sua “*cessão informal*” ao Senado teria perdurado até 1.7.2008, data em que remetido o Ofício n. 149/2008, da lavra do então Primeiro Secretário do Senado, senador Efraim Morais, comunicando formalmente ao Diretor de Recursos Humanos a devolução do impetrante aos quadros da AGU (eDOC 5, p.1). Tal ato, a seu ver, constituiria “*ato administrativo formal de devolução do servidor à Advocacia-Geral da União*”, não havendo que se falar em abandono de cargo uma vez que, até aquele momento o impetrante teria remanescido à disposição do Senado. Além disso, a devolução atendia também à determinação do próprio Diretor de Recursos Humanos da AGU de que o impetrante retornasse ao seu órgão de lotação até 1.7.2008 (Carta-DIRES/CGRH/DRHTI/SGAGU n. 140/2008 – eDOC 5, p.2).

Tal circunstância, diga-se de passagem, foi considerada na decisão por meio da qual restou concedida a tutela liminar pleiteada, ocasião em

RMS 38983 / DF

que se destacou que *“ante o reconhecimento da Administração de que houve cessão informal do impetrante para o Senado Federal, e de que enquanto essa situação perdurou não há falar em animus abandonandi, o ofício devolvendo o servidor para seu órgão de origem comprova, em princípio, que o empréstimo encerrou-se somente em 1º/7/2008”* (eDOC 23).

Nada obstante, conquanto o ofício de devolução formal do impetrante possa ser tido como indício de que a cessão informal perdurou para além da data considerada pela AGU para a aplicação da penalidade demissionária, como bem salientado por ocasião da concessão da liminar, entendo, diante das provas produzidas nos autos do PAD, que não pode ser considerado como marco do fim da prestação de serviços do impetrante ao Senado.

Isso porque o próprio impetrante admitiu, em depoimento, que prestou serviços ao Senado apenas até o final do mandato do senador Antero Paes de Barros (eDOC 37, pp. 16/19), informação igualmente corroborada por declaração prestada pela referida autoridade (eDOC 29, p. 3).

Adicionalmente, a invocação, pelo impetrante, da data de 1.7.2008 como data final da *“cessão informal”* apenas em virtude da formalidade mínima de que se revestiu o Ofício-PRSECR/Senado n. 149/2008 atenta, sobretudo em uma relação caracterizada por preponderante informalidade, contra o próprio comportamento processual do impetrante em sede administrativa, haja vista o seu requerimento, em 5/2/2007, de reingresso nos quadros da AGU.

Por outro lado, ao contrário do que fez a Administração para fins de aplicação da penalidade de demissão, igualmente não pode ser considerada como marco de *“cessação definitiva”* da prestação de serviços do impetrante ao Senado a data de 27.6.2006.

No particular, o exame tanto do relatório final da comissão de inquérito, quanto da nota técnica elaborada pela Corregedoria-Geral da AGU, revela que a Administração, ao considerar a data de 27.6.2006 como data de término da *“cessão informal”* do impetrante ao Senado, o fez a partir da presunção de que o simples fato de ter sido essa a data de

RMS 38983 / DF

publicação do último ato que tornou sem efeito a derradeira das nomeações do impetrante ao cargo de assessor parlamentar marcaria necessariamente o fim da prestação de serviços do impetrante junto ao Senado. **Tal presunção, todavia, vai de encontro ao contexto em que realizadas as sucessivas nomeações do impetrante ao cargo de assessor parlamentar e ao próprio raciocínio empreendido pela Administração quanto à situação funcional do impetrante antes de 2004. Em verdade, trata-se de raciocínio que desconsidera a notória informalidade que, como já salientado, marcou as relações ora analisadas.**

A esse respeito, o contexto das sucessivas tentativas de nomeação do impetrante no cargo de assessor parlamentar junto ao gabinete do então senador Antero Paes de Barros é bem retratado no ofício da Secretaria de Recursos Humanos do Senado Federal trazido aos autos pela própria União (eDOC 37, p. 11).

Conforme documenta o referido ofício, começando em 3.5.2004, verificou-se a edição de sete atos distintos de nomeação do impetrante em cargo de assessor parlamentar (Ato 772/2004, Ato 808/2004, Ato 1256/2004, Ato 2090/2004, Ato 4336/2005 e Ato 281/2006). No mesmo período, igualmente sobreveio a edição de seis atos que tornaram sem efeito os referidos atos de nomeação (Ato 1173/2004, Ato 1788/2004, Ato 312/2005, Ato 2853/2005, Ato 280/2006 e Ato 1509/2006).

A razão para a edição sucessiva de atos nomeando o impetrante ao cargo de assessor parlamentar, conjugada com a edição igualmente sucessiva de atos que tornaram sem efeito as referidas nomeações é bastante singela e reconhecida pela própria AGU: como nunca houve decisão acerca do pedido formal de cessão do impetrante ao Senado, o prazo de 30 (trinta) dias para posse previsto no §1º do art. 13 da Lei 8.112/1990 sempre se esgotava sem que o impetrante pudesse tomar posse no cargo em comissão na condição de servidor formalmente cedido pela AGU.

Isto é, todas essas nomeações se inseriram no contexto da tentativa de regularização da cessão informal discutida na espécie, o que somente não se efetivou porque a própria AGU nunca apreciou o

RMS 38983 / DF**pedido formal de cessão do impetrante ao Senado.**

Elucidativo notar, quanto ao ponto, que a primeira das nomeações somente veio a ser realizada, como adiantado, em 3.5.2004 (Ato 772/2004). Nada obstante, tal circunstância em nada impediu a AGU de considerar que o impetrante já se encontrava “*cedido informalmente*” ao Senado desde, pelo menos, novembro de 2002, ainda que de forma tida por ilegal. Isso se deu porque restou demonstrado que, malgrado os questionamentos acerca da legalidade da prática, o impetrante de fato esteve “*cedido informalmente*” ao Senado desde 2002.

Com efeito, em apreciação da documentação acostada aos autos, concluo que os mesmos elementos que autorizam a conclusão de que o impetrante encontrava-se, desde novembro de 2002, informalmente cedido ao gabinete do senador Antero Paes de Barros, igualmente conduzem à conclusão de que a referida prestação de serviços persistiu até o término do mandato do referido parlamentar (depoimento do impetrante – eDOC 37, pp. 16/19; declaração do parlamentar – eDOC 29, p. 3; ato de devolução do Senado – eDOC 5, p. 2), não subsistindo a presunção de que a prestação de serviços teria cessado definitivamente em 27.6.2006.

No particular, imperioso salientar que toda essa situação de incerteza e desordem administrativa foi potencializada – e deixou de ser definitivamente resolvida – por fato atribuível à própria AGU, que nunca apreciou o pedido formal de cessão do impetrante ao Senado.

Ainda que o órgão não tivesse interesse na referida cessão – o que certamente lhe era lícito – bastava responder negativamente à solicitação para que o impetrante, encerrando definitivamente a “*cessão informal*” até ali verificada, fosse então obrigado a se reapresentar ao seu órgão de origem sob pena de, aí sim, restar caracterizado inequívoco abandono de cargo.

A Administração, todavia, não procedeu dessa forma, permitindo a perpetuação de situação de inegável insegurança jurídica, não lhe sendo possível agora imputar ao servidor o ônus de tal confusão administrativa.

RMS 38983 / DF

Assim, tenho que o término do mandato parlamentar do então senador Antero Paes de Barros é que deve ser considerado como termo final da “*cessão informal*” verificada na espécie e da prestação de serviços do impetrante ao Senado – e não a data de 27.6.2006, considerada pela AGU para fins de aplicação da penalidade de demissão.

Impõe-se, dessa maneira, a conclusão de que o impetrante persistiu cedido informalmente ao Senado até 31.1.2007, data em que se encerrou o mandato do senador Antero Paes de Barros.

Digno de registro, quanto ao tema, o equívoco contido na Nota Técnica-CGAU/AGU n. 141/2009 (eDOC 9, p. 30), em que veiculado, a título de raciocínio subsidiário, que “*a permanência do Assistente Jurídico Joarez Gomes de Souza no Senado Federal só poderia se justificar até o término do mandato (SIC) do ex-Senador Antero Paes de Barros, QUE FINDOU EM 31/12/2006, momento a partir do qual o próprio servidor declarou ter se desligado em definitivo daquela Casa Legislativa*”, o que levou a Corregedoria-Geral da AGU a concluir que, “*mesmo na hipótese acima aventada, ainda assim teriam transcorridos mais de 30 dias consecutivos de ausência ao serviço até o dia 05/02/2007, caracterizando o abandono de cargo*”.

No particular, a nota técnica incorre em evidente erro material, uma vez que a posse dos novos membros do Senado, por força do § 4º do art. 57 da Constituição, somente se dá a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da respectiva legislatura, de modo que os mandatos então iniciados perduram por 8 (oito) anos contados dessa data. Nessa linha, na forma da norma constitucional em vigor, o então senador Antero Paes de Barros iniciou seu mandato em 1.2.1999 e permaneceu em exercício até 31.1.2007.

Deve ser considerado, então, que o impetrante permaneceu cedido informalmente ao Senado até 31.1.2007, tendo após se reapresentado formalmente a AGU meros cinco dias depois, em 5.2.2007.

Nesse contexto, adotando-se o raciocínio esposado pela própria comissão de inquérito do PAD no sentido de que não se pode considerar caracterizada a intencionalidade de abandonar o cargo no período em que o impetrante permaneceu informalmente cedido ao Senado, forçoso concluir que não há como entender caracterizada a

RMS 38983 / DF

infração funcional que motivou a aplicação da penalidade de demissão, pois decorridos apenas cinco dias – e não trinta – desde o término definitivo da “cessão informal” e a reapresentação do impetrante à AGU.

Inexiste, na espécie, o elemento subjetivo referente ao intuito de abandonar o cargo ocupado (Lei 8.112/1990, art. 138), uma vez que, após finalizada a prestação de serviços junto ao Senado, o impetrante se reapresentou ao órgão de origem meros cinco dias depois, sendo certo que, durante a referida prestação de serviços, diversas foram as tentativas promovidas pelas partes envolvidas de regularização da “cessão informal” verificada na espécie, o que apenas não se concretizou porque a solicitação formal de cessão do impetrante ao Senado nunca foi apreciada, conforme reconhecido pela própria AGU.

Razões que me levam a concluir que a aplicação da penalidade de demissão, na espécie, se deu em violação a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que, valendo-se de fundamentação inconsistente e contraditória, calcada em presunções não corroboradas pelo acervo fático-probatório dos autos do PAD, a União aplicou-lhe a penalidade de demissão deixando de considerar a data em que, segundo a documentação dos autos, efetivamente se deu o término de sua cessão informal ao Senado.

Ressalto, a propósito, que não se trata, aqui, de acolhimento de pretensão que pressupõe o “reexame do próprio mérito administrativo”, como aventado de forma genérica no acórdão recorrido. Não há incursão em suposto “*mérito administrativo*”, em primeiro lugar, porque o ato administrativo em questão é ato vinculado. Ato administrativo para cuja validade, como recorda Victor Nunes Leal, “*são pressupostos certos requisitos não só formais como também substanciais*” e que deve, portanto, ser motivado, baseando-se “*em determinadas ocorrências de fato sem as quais o ato seria uma conclusão aberrante das premissas*”. Nesse contexto, trata-se de ato sujeito a controle judicial, uma vez que a Administração, “*ao praticá-lo, tem seus poderes balizados por pressupostos definidos*”.

Como pontifica Victor Nunes Leal, no controle judicial dos atos

RMS 38983 / DF

administrativos de demissão de servidor público estável, *“a legalidade do ato administrativo compreende, não só a competência para a prática do ato e as suas formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato [...] a inconformidade do ato com os fatos que a lei declara pressupostos dêle constitui ilegalidade, do mesmo modo que o constitui a forma inadequada que o ato porventura apresente”* (LEAL, Victor Nunes. Atos administrativos - Exame da sua validade pelo poder judiciário. **Revista de Direito Administrativo**, v. 3, p. 69–98, 1946).

O controle judicial que ora se realiza nada tem a ver com o mérito administrativo cuja revisão é interdita ao Judiciário, intimamente relacionado a juízos de conveniência ou oportunidade na prática de determinado ato administrativo.

A aplicação da penalidade de demissão vincula-se ao cumprimento de prerrequisitos estritos previstos na legislação de regência, apurados mediante a apreciação das características particulares de cada caso concreto em sede de processo administrativo disciplinar. A caracterização de tais requisitos – mesmo aqueles relativos à devida apreciação do acervo fático-probatório do PAD – não se sujeita a juízos de conveniência ou oportunidade da Administração e, portanto, é sindicável pela via judicial.

II – CONCLUSÃO

Por todas essas razões, conheço do recurso ordinário interposto e dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade da Portaria-AGU n. 1.603, de 3 de novembro de 2009, por meio da qual restou aplicada ao impetrante a pena de demissão em virtude de suposto abandono do cargo então por ele ocupado.

Reconheço igualmente a ilegalidade, por arrastamento, dos atos administrativos eventualmente praticados com fundamento nos efeitos decorrentes da Portaria-AGU n. 1.603, de 3 de novembro de 2009, à exemplo do ato que cassou a aposentadoria voluntária concedida ao

RMS 38983 / DF

impetrante (Portaria-AGU n. 172/2021).

É como voto.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 38.983

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ANDRÉ MENDONÇA

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. GILMAR MENDES

RECTE.(S) : JOAREZ GOMES DE SOUZA

ADV.(A/S) : LENINE POVOAS DE ABREU (17120/O/MT)

RECDO.(A/S) : UNIÃO

PROC.(A/S) (ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Após o voto do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, diante da ausência de direito líquido e certo, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Segunda Turma, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.

Decisão: A Turma, por maioria, conheceu do recurso ordinário interposto e deu-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade da Portaria-AGU n. 1.603, de 3 de novembro de 2009, por meio da qual restou aplicada ao impetrante a pena de demissão em virtude de suposto abandono do cargo então por ele ocupado. Ademais, reconheceu igualmente a ilegalidade, por arrastamento, dos atos administrativos eventualmente praticados com fundamento nos efeitos decorrentes da Portaria-AGU n. 1.603, de 3 de novembro de 2009, à exemplo do ato que cassou a aposentadoria voluntária concedida ao impetrante (Portaria-AGU n. 172/2021), tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros André Mendonça (Relator) e Edson Fachin. Segunda Turma, Sessão Virtual de 3.11.2023 a 10.11.2023.

Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça.

Hannah Gevartosky
Secretária